

제28장

감정 · 검증 · 사실조회

제1절 감 정 210

제2절 검 증 248

제3절 사실조회(조사·송부의 촉탁) 266

제1절 감 정

1. 총 설

가. 의 의

감정이란 법관의 판단능력을 보충하기 위하여 전문적 지식과 경험을 가진 자로 하여금 법규나 경험칙(대전제에 관한 감정) 또는 이를 구체적 사실에 적용하여 얻은 사실판단(구체적 사실판단에 관한 감정)을 법원에 보고하게 하는 증거조사이다. 이와 같이 보고된 법규나 경험칙 또는 사실판단을 감정의 결과(감정의견)라 하고, 법원으로부터 감정을 명령받은 사람을 감정인이라고 한다.

감정의 목적이 될 수 있는 법규는 외국법규, 특정사회의 관습법 등이고, 사실판단에 관한 감정의 예로는 부동산 기타 재산권의 시가나 임대료, 토지의 경제측량, 공사의 하자의 유무와 그 정도 및 수리비용, 필적·인영·지문·사용된 잉크 또는 용지의 동일성, 사람의 정신상태, 사인, 상해의 부위와 정도, 향후치료 소요일수, 노동능력 상실정도, 컴퓨터프로그램의 동일성 등이다.

감정은 인증(人證)의 일종이므로 감정인이 작성한 감정서는 서증으로 취급해서는 안 된다. 그러나 소송 외에서 당사자가 직접 의뢰하여 작성된 감정서가 법원에 제출되었을 때에는 서증으로써 법원이 이를 합리적이라고 인정하면 사실인정의 자료가 될 수 있다(대법원 1999. 7. 13. 선고 97다57979 판결). 다만 사감정(私鑑定)이 법원의 감정 또는 감정촉탁에 의하여 얻은 그것에 못지않게 공정하고 신뢰성 있는 전문가에 의하여 행하여진 것이 아니라고 의심할 사정이 있거나 그 의견이 법원의 합리적 의심을 제거할 수 있는 정도가 되지 아니하는 경우에는 이를 쉽게 채용하여서는 안 되고, 특히 소송이 진행되는 중이어서 법원에 대한 감정신청을 통한 감정이 가능함에도 그와 같은 절차에 의하지 아니한 채 일방이 임의로 의뢰하여 작성한 경우라면 더욱더 신중을 기하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010다6222 판결). 즉,

이러한 사감정은 당사자의 기피권과 신문권이 보장되어 있지 아니하므로 전제사실이 법원이 인정한 사실과 부합하는지, 사실판단에 이르게 된 절차 등이 적절한지 등을 심사한 후 실질적 증거력을 판단하여야 한다.

감정인은 판단 등을 보고하는 사람이므로 대체성이 있는 데 비하여, 증인은 경험한 사실 등을 보고하는 사람이므로 대체성이 없다. 따라서 ① 증인은 당사자가 특정인을 지정하여야 하나(민소 308조), 감정인의 지정은 법원에 일임되어 있으며(335조), ② 증인능력에는 특별한 제한이 없으나, 감정인의 경우에는 결격사유에 관한 규정(334조 2항)과 기피에 관한 규정(336조)이 있고, ③ 불출석의 경우에는 증인은 감치하거나 구인할 수 있으나(311조, 312조), 감정인은 감치하거나 구인할 수 없고(333조 단서), ④ 자연인에 한정되는 증인과 달리, 감정은 법인에게도 촉탁할 수 있고(341조), ⑤ 증인진술은 말로 하는 것이 원칙이지만(331조), 감정의견의 진술은 서면 또는 말로 하며(339조 1항), ⑥ 증인신문은 교호신문방식으로 실시하지만(327조), 감정인신문은 법원 주도로 직권신문을 하면서 당사자의 보충신문권을 보장하는 방식으로 실시되고(339조의2), ⑦ 감정은 여러 사람에게 공동으로 의뢰할 수 있는 점(339조 2항)에서 증인과 다르다.

그러나 증인과 감정인은 인증이라는 점에서 공통점이 있으므로, 민사소송법 중 증인신문에 관한 규정(민소 311조 2항 내지 7항, 312조, 321조 2항, 327조 및 327조의2는 제외)을 준용하고(333조), 민사소송규칙 중 그 성질에 어긋나지 아니하는 범위 안에서 증인신문에 관한 규정을 준용한다(민소규 104조). 또한 증인신문과 감정인신문 모두 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용할 수 있다는 점에서 공통된다(민소 327조의2, 339조의3).

법원은 소송관계를 분명하게 하거나 증거조사 등 소송절차를 원활하게 진행하기 위하여 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 할 수 있다(민소 164조의2). 특수하고 복잡한

사안에 대한 감정 가능성, 감정신청의 적정성 판단, 감정사항의 확정 등과 관련하여 신속한 감정 절차 진행을 위하여 전문심리위원의 설명이나 의견을 들을 필요가 있는 경우에 전문심리위원제도를 활용함이 바람직하다. 그러나 전문심리위원의 기일에서의 설명이나 의견진술은 증거자료가 되지 아니하고(대법원 2014. 12. 24. 선고 2013다18332 판결), 이 점에서 감정과 차이가 있다.

나. 감정의무

감정에 필요한 학식과 경험이 있는 사람은 감정할 의무를 진다(민소 334조 1항). 다만 증언거부권(314조) 또는 선서거부권(324조)에 의하여 증언 또는 선서를 거부할 권리가 있는 사람과 선서무능력 사유(322조)에 해당하는 사람은 감정인이 되지 못한다(334조 2항).

감정의무에는 출석의무·선서의무·감정의견 보고의무의 3가지 내용이 포함되는데, 감정인이 이를 해태하면 증인의 경우에 준하여 소송비용의 부담 또는 500만 원 이하의 과태료 부과 등 제재가 가하여진다(민소 333조, 326조, 318조, 311조). 다만 감정인은 불출석하더라도 감치하거나 구인할 수 없다(333조 단서).

다. 감정절차 관리제도

(1) 의의 및 취지

전문가인 감정관리위원이 소송절차에 전문심리위원으로 참여하여 감정절차의 진행과 관련한 의견을 제시하도록 하고 감정담당판사와 감정관리위원이 감정인을 관리하도록 하는 감정절차 관리제도가 2025. 1. 1. 시행되었다(민소규 38조의11, 전심규 2조의4). 당사자와 법원의 전문성 부족, 감정인에 대한 관리부실 등으로 감정절차가 지연되고 부실한 감정이 이루어지는 것을 방지하기 위하여 전문가인 감정관리위원이 중심이 되어 감정절차와 감정인을 관리하여 감정이 신속하고 충실하게 이루어질 수 있도록 하는 취지이다.

감정절차 관리제도는 개별 사건에서 감정관리위원이 전문심리위원으로 참여하여 감정절차를 관리하는 것과 감정인을 일반적으로 관리·감독하는 것으로 구분될 수 있다.

감정관리위원은 민사·가사·행정 등 소송 사건에서 전문심리위원으로 참여할 수 있고, 형사사건에서는 참여할 수 없다(전심규 2조의4). 감정관리위원은 의료 및 건설분야에 위촉되어 있으므로, 감정절차 관리제도는 의료감정(신체감정과 진료기록감정)과 건설감정에 활용될 수 있다. 이는 임의적 절차로서 의료감정 또는 건설감정을 진행하는 사건 중 법원이 절차관리의 필요성을 고려하여 감정관리위원의 전문심리위원 참여결정을 하면 되나, 전문가에 의한 감정절차 관리를 통한 감정 충실화와 지연 방지, 감정인에 대한 전문적 관리 등을 위하여 적극적으로 활용할 필요가 있다.

감정절차 관리제도를 위하여 각 고등법원에 감정관리센터가 설치되어 있고 감정관리센터를 대표하고 행정사무를 총괄하는 감정담당판사와 전문가인 감정관리위원이 임명 또는 위촉되어 있다.

(2) 감정담당판사

광의의 감정담당판사는 감정관리센터를 대표하고 감정관리위원과 직원에 대한 관리와 감독을 하는 감정관리센터장과 센터장을 보좌하고 감정인에 대한 관리·감독 업무를 수행하는 협의의 감정담당판사로 구분된다.

감정담당판사는 ① 감정인평정표 및 감정인평정에 관한 의견을 수집하고 관리하여 감정인에 대한 실질적인 평가가 활성화되도록 하고, ② 평정과 평정에 관한 의견을 기초로 각급 법원에서 감정인 명단을 작성할 때 감정인 후보자 등재에 관한 의견을 제시하며, ③ 감정인이 불성실한 경우 등에는 감정인 명단에서 삭제하는 취지로 보고(감정예규 13조 1항, 16조 1항)할 수 있도록 하여 감정인 명단에 등재된 자에 대한 관리·감독 업무를 수행한다. 또한 ④ 감정인에 대한 교육과 ⑤ 감정관리위원 및 직원에 대한 관리 및 감독, ⑥ 그 밖에 감정절차의 개선을 위해 필요한 사무 등을 처리한다(감정예규 52조).

감정담당판사는 개별 소송사건의 감정절차에 관여하지는 않는다.

(3) 감정관리위원

감정관리위원은 해당 분야의 전문적인 지식과 경험을 가진 사람으로서 감정절차 관리업무를 수행한다. 감정관리위원과 상임전문심리위원은 겸하여 할 수 있고(전심규 2조의4), 현재 감정관리위원 전원이 상임전문심리위원을 겸직하고 있다.

감정관리위원은 구체적인 소송절차에서 재판장의 요구를 받아 ① 감정의 가능성과 필요성에 대한 설명 또는 의견진술, ② 감정을 하기 위하여 감정인에게 필요한 자격요건과 세부 전문분야에 대한 설명 또는 의견진술, ③ 감정인의 선정, 재선정 또는 지정에 관한 의견제시, ④ 감정인 후보자에 관한 의견제시[전산양식 A1800-2], ⑤ 감정사항 등의 의견제시, 필요한 자료제출 요청, ⑥ 감정료 증감에 관한 의견제시, ⑦ 예상감정료산정서의 적정성에 관한 의견제시, ⑧ 감정료산정서의 적정성에 관한 의견제시, ⑨ 감정절차의 진행 상황 보고[전산양식 A1800-3], ⑩ 그 밖에 감정절차의 진행을 위해 필요한 사항의 행위를 할 수 있다(감정예규 53조 2항). 재판장은 위 업무 중 전부 또는 일부에 관하여 선택하여 설명 등을 요구할 수 있다. 다만 감정관리위원은 재판장의 구체적인 설명 등 요구가 없더라도 ① 감정인의 업무 수행에 관한 감독, ② 감정절차 진행에 관한 당사자들의 의견조율, ③ 감정인 평정에 관한 의견제출[전산양식 A1800-1] 등의 업무를 재판장의 지휘를 받아 수행한다(감정예규 53조 1항).

(4) 감정관리위원의 전문심리위원 참여 절차

감정관리위원은 소송절차의 일부인 감정절차를 원활하게 진행하기 위하여 전문심리위원으로서 소송절차에 참여한다(민소 164조의2). 감정관리위원의 지정과 참여 절차는 전문심리위원과 기본적으로 동일하다. 아래에서 별도로 설명하는 부분을 제외한 나머지 구체적인 사항은 제24장(전문심리위원 제도) 참조.

감정관리위원회는 의료분야와 건설분야로만 구분하고 세부 전문분야(예: 정형외과, 내과 등)에 무관하게 감정관리센터가 소재하는 고등법원 권역의 감정 사건을 담당하는 것이 원칙이다. 감정관리위원회는 상임전문심리위원과 달리 기본적으로 절차를 관리하므로 세부 전문분야가 일치하지 않더라도 적절한 관리가 가능할 것이다. 사건의 실체에 대한 전문가로서의 설명 또는 의견이 필요한 경우에는 세부 전문분야를 고려하여 상임전문심리위원으로서의 참여결정을 할 필요가 있다.

감정관리위원의 지정에 대하여는 당사자의 의견을 들어야 하는데(민소 164조의4 1항), 의견청취서[전산양식 A1940-6 내지 A1940-9]를 전자우편 또는 팩시밀리 등을 활용하여 양쪽 당사자에게 보내거나 그 밖의 적절한 방법으로 당사자로부터 감정관리위원의 전문심리위원 지정에 관한 의견을 들어야 한다(전문심리예규 4조 3항). 당사자가 서면에 의하지 않고 감정관리위원의 전문심리위원 지정에 관한 의견을 표시하는 경우 법원사무관 등은 조서에 그 의견을 기재하거나 의견청취서 등에 의견 청취 방법과 의견의 취지를 적는 방식(예컨대, “20〇〇. 〇. 〇. 전화로 청취, 감정관리위원의 전문심리위원 지정에 관하여 양쪽 당사자 동의, 법원사무관 〇〇〇”) 또는 의견청취 보고서[전산양식 A1940-10]를 작성하여 기록에 편철하는 방식으로 의견 청취 사실을 표시하여야 한다(전문심리예규 4조 2항).

감정관리위원의 전문심리위원 참여결정을 한 이후 재판장은 감정관리위원에게 설명 등 요구서[전산양식 A1943-1]의 양식 중 요구할 사항을 적절히 가감하여 전자우편, 팩시밀리 등을 활용하여 보낸다(전문심리예규 5조 2항).

감정절차가 진행 중이면 감정관리위원의 참여결정이 가능하나, 통상 감정인을 누구로 지정할 것인지에 대한 의견을 제시하는 것이 감정절차 관리의 핵심이므로, 감정인 지정 전 단계인 감정신청서 접수 단계에서 감정관리위원 참여결정을 하는 것이 바람직하다.

2. 절 차

가. 신 청

감정은 법원이 직권으로 명할 수 있으나, 당사자의 신청에 의하여 행하는 것이 일반적이다. 감정을 신청함에 있어서는 감정을 구하는 사항을 적은 서면과 함께 증명취지와 감정대상을 적은 신청서를 내야 한다(민소규 101조 1항). 감정신청을 할 때에 감정인을 지정할 필요가 없으며, 그러한 기재가 있더라도 법원은 구속되지 않는다. 감정신청을 함에는 인지를 붙일 필요가 없다(인지 10조 단서).

감정은 증거조사결과가 기일 이전에 법원에 현출되어 상대방과 법원이 그 내용을 검토할 수 있도록 그 증거신청이 적시에 이루어져야 한다. 다만 뒤에서 보는 바와 같이 감정인에게 제시한 전제사실과 법원이 최종적으로 인정한 사실이 다를 경우에는 그 감정결과를 채택하는 것은 위법하므로 이 점에도 유의하여야 한다. 법원사무관 등은 전형적으로 감정신청이 필요하다고 판단됨에도 불구하고(예: 교통사고로 인한 손해배상사건에 있어 신체감정) 당사자가 필요한 감정신청을 하지 않는 때에는, 감정신청에 관한 안내서를 송부하거나, 전화 또는 팩시밀리로 신청을 촉구하여야 한다(감정예규 3조 1항).

감정이 필요한 전형적인 사건유형과 감정방법의 예를 들면 다음과 같다.

- ① 손해배상(자)·(산): 신체감정
- ② 손해배상(의): 진료기록감정(과실 유무)·신체감정
- ③ 보험금: 보험사고의 내용에 따라 신체감정 또는 시가감정
- ④ 공유물분할·경계확정: 측량감정
- ⑤ 부당이득금: 측량감정(점유부분 특정)·시가감정(임료)
- ⑥ 치료 등: 시가감정(임료)
- ⑦ 건물인도·건물철거·토지인도 등: 측량감정·유익비감정
- ⑧ 공사대금, 손해배상(건): 하자보수비감정·기성고감정

나. 증거의 채부결정

(1) 서 설

법원은 신청된 감정으로써 증명하려는 사실이 증명될 수 있고 그 사실이 쟁점판단에 필요하다고 판단되면 채택결정을 한다. 증거채부결정의 방식에 관하여는 제26장(증인) 참조. 다만 감정인은 특정하지 않은 채 감정을 하기로 한다는 취지의 결정만을 하는 것이 보통이다.

(2) 감정사항의 결정

감정사항은 신청인이 감정을 구하는 사항을 토대로 결정하는 것이 일반적이나, 예컨대 건축하자감정·신체감정과 같이 감정사항에 대하여 상대방의 의견제출이 예상되는 경우나, 환경사건(일조권)·공해사건·어업보상금사건 등에서 사고원인에 대한 감정을 실시하는 경우에 감정사항을 적절하게 결정하기 위해서는 감정사항을 정하기에 앞서 상대방에게 이에 관한 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여하는 것이 바람직하다.

그러므로 신청인이 감정을 구하는 사항을 적은 서면을 제출한 때에는 법원이 필요 없다고 인정한 경우(측량감정이나 시가감정과 같이 감정사항이 정형적으로 정하여져 있는 경우)가 아닌 한 그 서면을 상대방에게 송달하여야 한다(민소규 101조 1항, 2항). 상대방은 그 서면에 관하여 의견이 있는 때에는 의견을 적은 서면을 법원에 제출할 수 있는데, 이 경우 재판장은 미리 그 제출기한을 정할 수 있다(3항). 상대방에게 위 서면을 보내거나 상대방으로부터 의견을 제출받을 때에는 팩시밀리나 전자우편 등 간이한 송달방식을 적극 활용함으로써 절차를 신속하게 처리할 필요가 있다.

법원이 최종적으로 감정사항을 결정하는 때에는 기본적으로는 신청인이 감정을 구하는 사항을 기재한 서면을 토대로 하되, 이 서면에 대한 상대방의 의견과 필요한 때에는 감정인의 의견도 참작하여 감정사항을 정하게 된다(민소규 101조 4항). 감정사항을 정하는 경우에는 신청인이 제출한 감정신청서와 상대방의 의견서 등을 토대로 참여사무관등이 감정사항 초안을 작성하

여 재판장에게 보고하는 방식도 적극 활용할 필요가 있다.

(3) 감정사항에 대한 감정 가능성 고려

감정사항을 정함에 있어서 감정의 가능성을 고려하는 것이 당연한데, 그 자체가 전문적인 지식을 요하는 경우가 많아서 실무상 종종 문제가 된다. 가장 좋은 방법은 감정사항을 정함에 있어서 전문가의 조언을 받는 것으로서, 예를 들면 감정관리위원의 설명 또는 의견을 듣는다든지, 감정신청인에게 유관단체에 사실조회를 먼저 신청하도록 하는 방식을 취하는 것이다. 이러한 방식을 채택할 수 없는 사정이 있는 때에는, 감정사항을 정하기 전에 감정인의 의견을 반영한다든지 또는 감정을 명한 이후라도 감정사항을 수정하는 등의 운영방식이 필요하다.

(4) 전제사실의 확정과 필요한 자료의 제공

실제 사건에서 많이 이용되는 구체적 사실판단에 관한 감정은 어느 사실을 기초로 전문적 경험칙을 적용하여 판단하는 것인데, 여기서 감정인이 기초로 삼아야 할 구체적 사실인 전제사실을 전문지식이 부족한 법관이 정하기 어려운 경우에는 감정인에게 위임할 수밖에 없으나, 일반적인 경험칙에 의하여 전제사실을 인정할 수 있는 경우에는 법관이 증거에 의하여 인정되는 사실을 확정하고 이에 기하여 감정을 명하여야 한다. 예를 들어 의료과오 소송에서는 진료기록카드 등을 조사하거나 필요하다면 증인신문을 통하여 특정한 의료행위가 있었는지 여부를 미리 확정시켜 두는 것이 바람직하다.

법원은 전제사실을 인정하는 데 필요한 서증이나 그 밖의 참고자료(진료카드 등) 등 감정에 필요한 자료를 감정인에게 보낼 수 있고, 당사자는 감정에 필요한 자료를 법원에 내거나 법원의 허가를 받아 직접 감정인에게 건네줄 수 있다(민소규 101조의2 1항, 2항). 감정인은 부득이한 사정이 없으면 당사자가 법원의 허가 없이 직접 건네준 자료 등 위 절차에 따라 제공받은 자료가 아닌 자료를 감정의 전제가 되는 사실 인정에 사용할 수 없다(3항). 이러한 감정자료의 제출 및 사용 절차가 준수되는지를 사후적으로 확인하기 위하여

법원은 감정인에게 감정에 사용한 자료를 제출하게 하거나 그 목록을 보고하게 할 수 있다(4항).

절차진행단계에서 불가피하게 구체적 전제사실을 확정할 수 없는 상태에서 감정을 명하는 경우에는 상대방의 의견 등을 참작하여 복수의 전제사실을 기재하여 감정을 명하는 방법 등을 활용하는 것도 이용될 수 있다. 만약 감정인에게 제시한 전제사실과 법원이 최종적으로 인정한 사실이 다를 경우에는 그 감정결과는 적절하지 않으므로 증거로 사용하여서는 아니 된다.

부득이한 사정이 있어 전제사실의 확정을 감정인에게 위임한 경우에는 감정인은 감정결과뿐만 아니라 어떤 전제사실에 기하여 전문적 경험칙을 적용하여 감정결과를 얻었는지를 감정서에 자세히 기재하여야 한다.

[진료기록 감정사항 기재례]

감 정 사 항

1. 기초사실

- 가. 피고병원에 내원하기 전 환자의 병력
- 나. 내원 당시의 증상
- 다. 위 병력 및 증상을 기초로 피고병원 의사들이 내린 진단 결과
- 라. 환자에 대하여 시행한 검사의 종류 및 결과
- 마. (소규모 병원일 경우) 피고병원에 소속된 의사의 수 및 전공과목, 간호사·간호조무사의 수, 병실의 개수, 진료기기의 구비 여부

2. 진료과정과 관련

- 가. 피고병원 의사들의 과실 여부에 대한 양 당사자의 주장을 제출한 소장, 준비서면 등(뒤에 첨부됨)에 기초하여 의학적으로 간략하게 정리 요망
 - ① 환자 측 주장
 - ② 병원 측 주장
- 나. 긴급성의 유무(치료가 시간적으로 긴급을 요하였는지, 또는 치료과정이 극히 위험하나 그대로 방치할 수 없어 치료를 시작한 것인지 여부) 및 그 정도
- 다. 내원 당시의 임상의학수준(의학문헌)에 기초하여,
 - ① 내원 당시의 증상에 대한 일반적인 치료방법의 내용 및 필요성, 예후 및 예상되는 위험과 부작용, 그 발생확률(%)

- ② 피고병원 의사들이 환자에 대하여 시행한 외과적, 내과적 치료를 포함한 모든 진료행위의 경과(특히 위 진료행위 중 이 사건의 의학적 핵심이 되는 부분에 관하여 시간적 순서에 따라 기재 요망)
 - ③ 위 진료과정(진단, 검사, 치료, 경과관찰 등)에서 일반적으로 의사들이 주의하여야 할 점(특히 위 진료행위 중 이 사건의 의학적인 핵심이 되는 부분에 관하여 중점적으로 설명 요망)
- 라. 위 다.의 ②, ③항에 비추어 볼 때, 결과적으로 피고병원 의사들의 진료가 적절하였는지 여부, 부적절하였다면 구체적으로 어떠한 점을 지적할 수 있는지
3. 본건 진료행위 중 발생한 나쁜 결과 및 현재의 나쁜 결과와 관련하여
- 가. 위 각 나쁜 결과에 대한 의학적 진단명, 일반적인 발생원인, 각 원인별 발생 가능성 및 정도(%)
- 나. ① 위 원인 중 본건 진료행위와 관련성이 있는 것, 그 이유
 위 원인 중 본건 진료행위와 관련성이 없는 것, 그 이유
- ② 본건 진료행위로 인하여 위 각 나쁜 결과가 발생할 가능성 및 그 정도(%)
- 다. 진료 당시의 의학수준에 비추어,
- ① 진료 당시 위 각 나쁜 결과의 발생을 예견할 수 있는지 여부, 예견 가능하였다면 이를 예방할 가능성이 있는지 여부, 있다면 어떠한 조치를 취하여야 하는지
- ② 위와 같은 예방조치를 취하였을 경우 위 각 나쁜 결과의 발생을 막을 수 있었는지 여부 및 막을 수 있는 확률(%)
4. 기왕증과 관련
- 가. 환자가 피고병원에 내원하기 전 기왕증이 있었는지 여부, 있었다면 그 의학적 진단명
- 나. 기왕증이 있었다면 위 기왕증이 환자의 현 증상에 영향을 미쳤는지 여부 및 그 정도(가능하면 %로 표시)
- 다. 일반적으로 위 기왕증은 완치가 가능한 것인지 여부
- 라. 완치가 불가능하다면 ‘적절한 치료를 마친 상태에서’ 일반적으로 위 기왕증 자체만으로 노동능력의 상실, 기대여명의 단축을 예상할 수 있는지 여부, 예상 가능하다면 구체적인 예상 수치<노동능력상실의 경우 그 상실 정도를 맥브라이드표에 의해 산정하여 수치(%)로 표시 요망>
5. 기타 당사자 쌍방이 제출한 감정사항(위 내용과 중복되지 않는 범위 내에서 답변 요망)
- <참고> 병명 등 의학용어는 가급적 국어, 한자어, 원어를 병기하여 주시고 간단한 개념 설명을 덧붙여 주시기 바랍니다.
- 예) 한랭감(寒冷感, psychroesthesia, 신체의 일부가 따뜻하지만 차게 느끼는 상태)

다. 감정인의 지정

(1) 개 설

감정인은 수소법원, 수명법관 또는 수탁판사가 지정한다(민소 335조). 감정인은 학식과 경험이 있는 자 중에서 지정하여야 하고, 반드시 감정을 직업으로 하거나 감정사항을 전문적으로 또는 직업적으로 취급하는 사람일 필요는 없지만 감정인으로서의 전문성과 공정성을 갖추어야 한다. 감정인의 지정에 관하여는 ‘감정인등 선정과 감정료 산정기준 등에 관한 예규’가 제정되어 있다. 감정인은 법원행정처에서 운영하는 ‘감정인선정전산프로그램’에 의하여 선정함이 원칙이나 양쪽 당사자가 합의하여 감정인선정신청을 하는 경우에는 그에 따르면 된다. 또한 ‘감정인등 선정과 감정료 산정기준 등에 관한 예규’ 47조에 따라 법원행정처(소관: 사법지원실)에서 ‘특수분야 전문가 명단’을 작성, 관리하고 있으므로, 이 자료를 통해서도 적합한 감정인을 선정할 수 있다(감정예규 49조 1항).

제28장

감정 · 검증 · 사실조회

[전산양식 A1797] 감정인추천의뢰

○ ○ 법 원 감 정 인 추 천 의 료

귀하

사 건 20○○가단1000 매매대금
원 고
피 고

위 사건의 심리에 필요하여 아래 감정사항에 관한 감정을 하고자 하오니 귀 협회 소속 전문의 1인을 감정인으로 추천하여 주시기 바랍니다.

감정사항: 별지와 같음

※ 이 법원에 제출하는 서면에는 당원의 사건번호(20○○가단1000 매매대금)를 반드시 기재하여 주시기 바랍니다.

20○○. ○. ○.
판사 ○ ○ ○ ㉠

‘감정인선정전산프로그램’이나 ‘특수분야 전문가 명단’에 의하여 감정인을 선정할 수 없는 경우에는 그 선정에 공정을 기하기 위하여 재판장이 유관단체에 추천을 의뢰하고[전산양식 A1797], 그 추천에 의하여 감정인을 선정하는 것이 보통이다.

감정인이 정해지면 감정인지정결정을 한다. 변론(준비)기일 외에서 결정하는 것이 보통인데, 감정인지정결정서[전산양식 A1780]를 작성하여 기록에 철하고 결정서 등본을 해당 감정인에게 송달한다(후술하는 출석요구서와 함께 송달함이 보통이다). 변론(준비)기일에 감정인지정결정을 하는 경우 이러한 법원의 결정은 소송지휘권에 의한 재판으로서 조서의 필수적 기재사항이다(민소 154조 5호 참조). 따라서 변론(준비기일)조서에는 “시가감정인으로 ○○○을 지정한다고 결정 고지”로 기재하고, 증인등목록의 ‘증거결정’란에는 “(준비)○차”, ‘증거조사’란에는 “감정인 ○○○ 지정” 등으로 기재한다.

법원은 감정인을 지정하였더라도 감정을 명하기 전이라면 감정인 지정을 취소할 수 있고, 감정을 명한 후라도 감정서를 제출하지 않거나 구술로 감정 보고를 하기 전까지는 감정인 지정을 취소할 수 있다. 이 경우에도 감정인에게 감정에 소요된 일당, 여비 등은 지급하여야 한다(민소비용 4조).

지정된 감정인은 자신에게 주어진 감정을 시행할 역량이 있는지를 검토하여 감정사항이 자신의 전문분야에 속하지 아니하는 경우 또는 그에 속하더라도 다른 감정인과 함께 감정을 하여야 하는 경우에는 곧바로 법원에 감정인의 지정 취소 또는 추가 지정을 요구하여야 한다(민소 335조의2 1항). 감정인은 감정을 다른 사람에게 위임하여서는 아니 된다(2항).

간혹 당사자 측에서 감정인의 편향성이나 불공정성 등에 관한 의혹을 제기하면서 특정 감정인의 지정 배제나 지정된 감정인의 교체를 요구하는 경우가 있다. 감정인의 편향성 등에 대한 의혹은 해당 감정인의 개인적 성향에서 비롯된 경우와 그 감정인이 속한 직군의 직업적 요인에서 비롯된 경우로 나누어 볼 수 있는데, 어느 경우든 막연한 의혹이나 주장만으로 감정인 지정

배제나 감정인 지정취소를 할 수는 없고, 그 사유를 소명할 수 있는 구체적 사실과 자료가 제시되어야만 그러한 조치가 고려될 수 있다.

(2) 신체감정 및 진료기록감정

법원행정처장은 국·공립병원 및 대학부속병원 또는 종합병원에서 추천한 과장 또는 조교수 이상의 전문의 중에서 적절하다고 판단되는 사람을 신체 감정 및 진료기록감정 분야로 나누어 '감정촉탁기관 및 감정과목별 담당의사 명단'에 등재하고 '감정인선정전산프로그램'에 입력하여야 한다(감정예규 6조). 또한 법원행정처장은 국·공립병원 및 대학부속병원에서 10년 이상 임상경험이 있는 전문의로서 해당 병원에서 퇴직한 지 10년이 경과되지 아니한 사람 중에서 적절하다고 판단되는 사람을 '감정인선정전산프로그램'의 '진료기록감정인 명단'에 등재한다(감정예규 6조의2). 위 감정인은 개인 감정인이므로 감정촉탁에 의할 수 없고 감정인신문을 거쳐야 한다. 진료기록감정인에 대한 감정인신문은 영상재판을 원칙으로 한다(감정예규 15조의2 6항).

신체감정 및 진료기록감정은 개인 감정인을 제외하고는 특별한 사유가 없는 한 감정촉탁의 방법에 의하고, 이 경우 재판부는 위 전산프로그램을 이용하여 주과목과 보조과목별로 감정인을 지정하고 위 병원에 감정촉탁하되, 재감정의 경우에는 국·공립병원의 과장 또는 대학의 조교수급 이상의 전문의를 감정인으로 선정하여 재감정을 명할 수 있다(감정예규 14조 2항).

감정절차 관리제도를 활용하는 경우 감정관리위원회는 재판장의 요구에 따라 감정을 위하여 요구되는 세부 전문 분야, 경력 등을 고려하여, ① 신체감정의 경우 '감정촉탁기관 및 감정과목별 담당의사 명단'에서 적절한 감정촉탁기관 및 담당의사 후보자를 선택한 후 감정 희망 의사 등을 확인하여 재판장에게 감정촉탁기관 및 감정과목별 담당의사의 선정에 관한 의견을 제시하고(감정예규 15조 2항), ② 진료기록감정의 경우 '감정촉탁기관 및 감정과목별 담당의사 명단'에서 적절한 감정촉탁기관 및 담당의사 후보자를 선택하거나 '진료기록감정인 명단'에서 적절한 진료기록감정인 후보자를 선택한 후

감정 희망 의사 등을 확인하여 재판장에게 감정인 선정에 관한 의견을 제시한다(감정예규 15조 2항, 15조의2 2항). 이는 감정관리위원으로 하여금 사전에 감정에 필요한 세부 전문 분야, 경력, 감정의의 감정 희망 의사 등을 확인하도록 하여 감정결과의 전문성을 높이고 감정촉탁서 반송으로 인한 절차 지연을 방지하기 위함이다. 이 경우 ‘감정인선정전산프로그램’에 의하여 선정할 필요가 없다(감정예규 4조, 15조 1항의 예외). 신체감정 또는 진료기록감정에서 감정사항에 비추어 적합한 자격을 갖춘 사람이 ‘감정촉탁기관 및 감정 과목별 담당의사 명단’ 또는 ‘진료기록감정인 명단’에 등재되어 있지 않은 경우에는 감정관리위원은 관련 의학회 등에 후보자 추천을 의뢰하는 등 적절한 방법으로 적격자를 물색하여 감정인 선정에 관한 의견을 제시한다(감정예규 15조 3항, 15조의2 3항).

복수의 감정 과목에 대한 신체감정촉탁 결과에는 감정의 중복·누락이 있을 수 있으므로, 신체감정촉탁 결과에 의하여 노동능력상실률을 평가하는 법원으로서 감정이 중복·누락되었는지 여부를 세심히 살펴야 하고, 중복·누락이 있는 경우에는 필요한 심리를 통하여 이를 바로잡아야 한다(대법원 2020. 6. 25. 선고 2020다216240 판결).

(3) 공사비등의 감정

공사비, 유익비, 하자보수비, 건축물의 구조, 공정, 그 밖에 이에 준하는 사항의 감정을 위한 공사비등의 감정인으로 등재되는 사람은 건축사·건축구조기술사·건축시공기술사 등의 국가기술자격을 가진 사람으로서 소속단체(대한건축사협회 등)가 추천한 사람 또는 본인이 신청한 사람이어야 한다. 법원행정처장은 공사비등의 감정인이 되고자 감정인후보자 등재 신청을 한 자 중에서 각급 법원 및 지원에서 감정인으로 적정하다고 평가하여 등재 요청을 한 자를 승인하여 ‘감정인선정전산프로그램’의 ‘감정인 명단’에 등재한다(감정예규 5조). 공사비등의 감정을 하는 경우 담임 법원사무관 등은 ‘감정인선정전산프로그램’을 이용하여 감정인을 선정하여야 하고, 법원은 특별한

사정이 없는 한 그에 따라 선정된 사람을 감정인으로 지정하여야 한다(감정예규 9조 1항).

감정절차 관리제도를 활용하는 경우 감정관리위원회는 재판장의 요구에 따라 감정을 위하여 요구되는 세부 전문 분야, 자격증, 경력 등을 고려하여 '감정인선정전산프로그램'에 의하여 2인 또는 3인의 감정인 후보자를 선정한다. 다음 감정인 후보자의 예상감정료 및 당사자의 의견 등을 종합하여 재판장에게 감정인의 지정에 관한 의견을 제시한다(감정예규 25조 1항 3호). 만약 감정사항에 비추어 적합한 자격을 갖춘 사람이 '감정인 명단'에 등재되어 있지 않은 경우에는 감정관리위원회는 유관단체에 추천을 의뢰하는 등의 방법에 의하여 적격자를 선정하여 의견을 제시한다(감정예규 25조 1항 3호, 4호).

(4) 문서등의 감정

필적·문서·인영·문자·지문등의 감정을 위한 문서등의 감정인은 입체 형미경 등의 시설·장비를 갖추는 등 인적·물적 자격을 갖추어야 한다. 법원행정처장은 문서등의 감정인이 되고자 감정인후보자 등재 신청을 한 자 중에서 각급 법원 및 지원에서 감정인으로 적정하다고 평가하여 등재 요청을 한 자를 승인하여 '감정인선정전산프로그램'의 '감정인 명단'에 등재한다(감정예규 5조). 법원행정처장은 문서등의 감정인이 되고자 감정인후보자 등재 신청을 한 사람에 대하여 숙련도 평가를 실시하여 자격심사 결과가 포함된 감정인 후보자 명단을 각급 법원 및 지원에 송부할 수 있다(감정예규 5조의2). 문서등의 감정을 하는 경우 담임 법원사무관 등은 '감정인선정전산프로그램'을 이용하여 감정인을 선정하여야 하고, 법원은 특별한 사정이 없는 한 그에 따라 선정된 사람을 감정인으로 지정하여야 한다(감정예규 9조 1항).

(5) 측량감정

토지분할측량, 경계복원측량, 현황측량, 그 밖의 일반측량 등의 감정을 위한 측량감정인은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 따라 등록된 지적측량업자 또는 그 소속 지적기술사·지적기사·지적산업기사의 자격을

갖추어야 한다. 법원행정처장은 측량감정인이 되고자 감정인후보자 등재 신청을 한 사람 중에서 각급 법원 및 지원에서 감정인으로 적정하다고 평가하여 등재 요청을 한 사람을 승인하여 ‘감정인선정전산프로그램’의 ‘감정인 명단’에 등재한다(감정예규 5조).

민사소송에서 이용되는 측량감정은 ① 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 따른 지적측량 중 경계점좌표등록부가 비치된 지역(수치지역)에서의 지적측량, ② 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 따른 지적측량 중 경계점좌표등록부가 비치되지 않은 지역(도해지역)에서의 지적측량, ③ 각종 공작물의 형태, 종·횡단, 고저측량 등 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 의한 일반측량으로 구분된다. 측량감정을 하는 경우 재판부는 ①의 경우에는 한국국토정보공사의 본사·본부·지사에 감정을 촉탁하거나 ‘감정인선정전산프로그램’을 이용하여 감정인을 선정하면서 감정을 명하고, ②의 경우에는 한국국토정보공사의 본사·본부·지사에 감정을 촉탁하며, ③의 경우에는 공간정보산업협회의 본부·지부·출장소에 감정을 촉탁하거나 그로부터 추천받은 감정인에게 감정을 명한다(감정예규 17조).

(6) 시가등의 감정

토지, 건물, 동산 그 밖의 재산에 대한 시가 또는 임료 등에 대한 감정, 토지수용으로 인한 손실액의 산정을 위한 감정의 감정인은 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따라 감정평가사무소 개설신고를 한 감정평가사라는 자격을 갖추어야 한다. 법원행정처장은 한국감정평가사협회가 추천한 감정평가사(각급 법원 및 지원의 부적격 의견 등 특별한 사유가 있는 경우는 제외)나 법원장 또는 지원장이 감정평가사 중에서 적절하다고 판단하여 등재 요청한 사람을 ‘감정인선정전산프로그램’의 ‘감정인 명단’에 등재한다(감정예규 5조). 시가등의 감정을 하는 경우 담임 법원사무관 등은 ‘감정인선정전산프로그램’을 이용하여 감정인을 선정하여야 하고, 법원은 특별한 사정이 없는 한 그에 따라 선정된 사람을 감정인으로 지정하여야 한다(감정예규 9조 1항).

(7) 특수분야 감정

법원행정처장은 각급 법원 및 지원에서 특수분야 전문가를 감정인으로 선정하는 업무를 지원하기 위하여 ‘특수분야 전문가 명단’을 전산으로 작성·관리한다. 각급 법원 및 지원의 재판장은 ‘특수분야 전문가 명단’에 감정업무 수행을 위해 필요한 전문가가 등재되어 있지 아니한 경우에 소장부분 등을 첨부하여 법원행정처장에게 해당 특수분야 전문가를 찾아 명단에 등재하여 줄 것을 요청할 수 있고, ‘특수분야 전문가 명단’을 활용하여 해당 전문가를 감정인으로 선정할 수 있다(감정예규 47, 48조).

제28장

감정 · 검증 · 사실조회

라. 감정인에 대한 출석요구 및 당사자에 대한 기일통지

감정인이 정해지면 지정된 신문기일에 출석하도록 하여야 하는데, 출석요구의 방식은 증인의 경우와 동일하다. 감정인출석요구서(전산양식 A1632)의 빈칸에 해당 사항을 기재한 후, 별지로서 감정사항을 기재한 서면을 첨부하여 송달하여야 한다. 감정인지정결정등본을 송부할 필요는 없다. 감정인은 법정이나 기타 적당한 장소로 출석하도록 하는데, 현장검증과 동시에 감정을 명하는 경우에는 검증현장으로 출석하게 할 수 있다.

한편 이러한 감정인신문기일은 증인신문기일과 마찬가지로 일종의 증거조사기일이므로 당사자들에게도 감정인신문기일에 출석할 수 있도록 기일통지를 하여야 한다. 다만 이러한 기일통지는 팩시밀리나 전화 등의 간이한 통지방법을 활용하여도 무방하다.

마. 감정인신문과 선서

감정인신문은 두 가지 의미가 있다. 감정인에게 최초로 출석을 요구하여 선서를 시킨 후 감정사항을 알리고 감정을 명하는 것과 감정인이 감정결과를 서면으로 제출한 후 법원에 대하여 보충진술을 하는 것이 그것이다. 어느 경우든 시행방식에 관하여는 동일한 원칙이 적용되는데, 여기서는 전자에

관하여 설명한다.

출석한 감정인의 동일성 확인, 거짓감정의 별의 경고, 선서, 감정거부·선서거부의 경우의 처리에 관하여는 모두 증인신문에 관한 규정이 준용되므로 전술한 증인신문에 관한 각 설명을 참조하면 된다. 다만 선서서는 별도의 양식[전산양식 A1671]이 정하여져 있고(민소 338조, 333조 단서), 법원은 감정인에게 선서를 하게 하기에 앞서 감정사항이 자신의 전문분야에 속하지 아니하는 경우 또는 그에 속하더라도 다른 감정인과 함께 감정을 하여야 하는 경우에는 곧바로 법원에 감정인의 지정 취소 또는 추가 지정을 요구하여야 하고 감정을 다른 사람에게 위임하여서는 아니 됨을 알려야 한다(335조의2, 민소규 100조의2).

선서하지 아니한 감정인에 의한 감정결과는 증거능력이 없으므로, 이를 사실인정의 자료로 삼을 수 없다 할 것이나, 법원이 감정인을 지정하고 그에게 감정을 명하면서 착오로 감정인으로부터 선서를 받는 것을 누락함으로써 말미암아 그 감정인에 의한 감정결과가 증거능력이 없게 된 경우라도, 그 감정인이 작성한 감정결과를 기재한 서면이 당사자에 의하여 서증으로 제출되고, 법원이 그 내용을 합리적이라고 인정하는 때에는, 이를 사실인정의 자료로 삼을 수 있다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2005다77848 판결).

또 감정인에 대하여 법정으로 출석을 요구하지 않고 법원 밖으로 출석을 요구하거나, 감정인의 현재 장소로 법원 또는 수명법관이 출장하여 신문할 수 있음도 증인신문의 경우와 같다.

감정인은 재판장이 신문하고(민소 339조의2 1항), 당사자는 재판장에게 알리고 신문할 수 있다(3항). 다만 당사자의 신문이 중복되거나 쟁점과 관계가 없는 때, 그 밖에 필요한 사정이 있는 때에는 재판장은 당사자의 신문을 제한할 수 있다(3항 단서). 합의부원은 재판장에게 알리고 신문할 수 있는데(2항), 조서에는 “판사 ○○○”라고 기재하면 되고 ‘재판장에게 알리고’를 기재할 필요가 없음은 증인신문의 경우와 같다.

감정인신문을 행한 때에는 조서를 작성하여야 하는데(민소 154조 2호), 감정인신문조서[전산양식 A1664]는 이를 기일조서[전산양식 A1662] 또는 변론(준비 기일)조서에 첨부하는 것이 바람직하다. 이 경우 기일조서 등을 색지로 사용하므로 감정인신문조서에는 색지를 사용할 필요가 없다(조서예규 6조 3항).

통상 감정인신문조서에는 아래 문례와 같이 재판장이 직권으로 학력·경력·감정경험의 유무 등 감정을 명함에 적합한 능력이 있는지 여부를 확인하는 내용의 신문을 먼저 행한 다음, 출석한 당사자에게 신문의 기회를 부여하고(실제로는 당사자가 별다른 신문을 하지 않는 것이 보통이다), 다시 재판장이 감정사항을 고하고 감정을 명하였다는 식으로 기재한다.

[전산양식 A1664] 감정인신문조서

○ ○ 법 원 감 정 인 신 문 조 서

사 건 20○○가
감 정 인 이 름
생 년 월 일
주 소

판 사

감정인에게 선서의 취지를 명시하고 허위감정의 벌을 경고한 다음, 별지 선서에 의하여 선서를 하게 하였다.

1. 감정인은 원, 피고를 모른다.

판 사

1. 감정인은 법원의 명에 의하여 감정평가한 경험이 있음.

판 사

감정인에게
감정인
위 명에 응락.

법원주사

판 사

제28장

감정 · 검증 · 사실조회

바. 감정에 필요한 처분

토지·건물 등의 측량감정의 경우와 같이 감정을 위하여 타인의 토지나 건물 그 밖의 시설물 안에 출입할 필요가 있는 때가 있다. 그런데 감정인의 출입에 반대의 이해관계가 있는 당사자나 제3자에 의하여 감정인이 그 토지나 건물 등에 들어가지 못하게 되면 감정이 불가능하게 된다. 이러한 경우에 대비하여 민사소송법은 감정인이 감정을 위하여 필요한 경우에는 법원의 허가를 받아 남의 토지, 주거, 관리중인 가옥, 건조물, 항공기, 선박, 차량 그 밖의 시설물 안에 들어갈 수 있고, 이 경우 감정인이 저항을 받았을 때에는 경찰공무원에게 원조를 요청할 수 있도록 하고 있다(민소 342조).

[전산양식 A1806] 허가결정서

○ ○ 법 원 결 정		
사 건	20○○가단○○ 손해배상(기)	
원 고	○○○	
피 고	○○○	
감 정 인	○○○	
주 문		
위 사건에 관하여 감정인에게 20○○. ○. ○. : 부터 20○○. ○. ○. : 까지 (들어갈 장소)에 대한 출입을 허가한다.		
이 유		
위 사건에 관하여 감정을 위하여 필요하다고 인정되므로 민사소송법 제342조 제1 항에 의하여 주문과 같이 결정한다.		
20○○. ○. ○.		
판 사 (인)		
※ 감정인이 감정을 위하여 주문에 기재된 장소에 들어가려고 하였으나 소송당사자 나 제3자의 저항을 받았을 경우에는 경찰공무원에게 원조를 요청할 수 있습니다.		

감정인이 타인의 토지나 주거 등에 들어가기 위하여는 우선 법원의 허가를 얻어야 한다. 민사소송법 342조 1항이 감정인에게 허가신청권을 부여한 것은 아니므로, 법원은 허가가 필요 없다고 인정하는 경우에는 허가를 하지 않으면 되고 별도로 신청을 기각하는 재판을 할 필요는 없으며 감정인에게 사실상의 통지를 하면 족하다. 법원이 허가를 하는 때에는 결정서에 사건의 표시, 감정인의 표시, 들어갈 장소, 유효기간 등을 기재하여 허가의 범위를 명시하여야 한다. 감정인은 출입 시에 허가결정서 정본을 제시하여야 하고, 그럼에도 불구하고 당사자나 제3자의 저항을 받았을 때에는 경찰공무원에게 원조를 요청할 수 있다.

사. 감정인의 의견진술과 감정인신문

재판장은 감정인으로 하여금 서면이나 말로써 의견을 진술하게 할 수 있고(민소 339조 1항), 여러 감정인에게 감정을 명하는 경우에는 다 함께 또는 따로따로 의견을 진술하게 할 수 있다(2항). 실무상으로는 감정의견을 서면에 기재하여 제출하게 하는 것이 보통인데, 이 서면을 감정서라 한다. 감정인에게 서면으로 감정의견을 제출하게 하는 경우에는 다음 절차의 신속한 진행을 위하여 그 제출기한을 명확히 고지하는 것이 바람직하고, 이후로도 참여사무관등을 통하여 그 기한을 철저히 관리하여 불필요하게 절차가 지연되지 않도록 유의하여야 한다.

감정서의 방식에 대하여 법률상 특별한 규정은 없으나, 감정의견의 결론과 그에 이르게 된 이유를 기재하고 감정서 작성 연월일을 기재하고 서명날인하는 것이 보통이다. 법원이 감정을 명하거나 감정을 촉탁하는 때에는 감정서의 부분을 제출하게 하거나(민소규 76조), 감정서의 전자파일을 전자우편이나 그 밖에 적당한 방법으로 법원에 보내도록 요청할 수 있다(48조 2항). 전자기록사건에서 감정인이 감정서를 전자데이터 또는 전자문서로 작성한 경우에는 전자소송시스템을 이용하여 이를 전송하여야 하고(민전규 37조 1항),

법원은 감정서가 전자데이터 또는 전자문서가 아닌 경우 이를 전자문서로 변환하여 전송하여 줄 것을 요청할 수 있다(2항). 전자소송에 동의하지 않은 당사자가 있을 경우 통상 우체국이 전자파일을 받아 직접 출력하여 이를 송달하는 전자우편(우편법 15조 3항, 우편법 시행규칙 25조 1항 12호) 제도를 이용하고 있으나(이른바 ‘e-post 방식’), 150장을 초과하는 경우 이를 이용할 수 없다. 이 경우 민사소송규칙은 법원이 필요한 경우 감정인으로부터 원본과 동일한 부분을 제출받아 이를 활용할 수 있도록 부분제출 요구의 근거를 명시하고 있으므로, 이를 활용할 수 있을 것이다.

감정서는 감정사항에 대한 결과뿐만 아니라 그에 이르게 된 경위와 과정을 자세히 기재하여야 한다. 전제사실을 감정인에게 위임한 경우에는 어떠한 근거에서 어떠한 전제사실을 기초로 전문지식을 적용하여 감정결과를 얻었는지를 자세히 기재하여야 한다.

법원은 감정인이 서면으로 감정의견을 제출한 경우에도 그에 관하여 말로 설명하게 할 필요가 있다고 인정하는 때에는 기일지정·출석요구 등의 절차를 거쳐 감정인을 법정에 출석하게 하여(민소규 101조의3 2항) 감정인신문을 할 수 있다. 기일에는 종전에 한 선서의 효력이 유지됨을 알리고 별도로 선서를 하게 하지 아니하여도 무방하다. 여기서 말로 설명할 필요가 있다고 인정되는 때로는, 서면으로 제출된 감정의견에 모순되거나 불분명한 사항이 있는 경우, 추가적인 서면 의견진술을 제출받는 방법으로는 효율적인 심리가 곤란하거나 소송이 지연될 우려가 있는 경우 등을 들 수 있다. 법원은 당사자에게 기한을 정하여 감정인에게 질문할 사항을 적은 서면을 감정인이 출석할 신문기일 전에 제출하게 할 수 있고(3항), 법원사무관등은 그 서면의 부분을 감정인이 출석할 신문기일 전에 상대방에게 송달하여야 한다(4항). 이와 같이 감정인신문을 실시한 경우에는 감정서와 감정인신문결과가 일체로서 감정의견을 구성한다고 봄이 타당하다.

쟁점을 중심으로 한 집중적이고 효율적인 감정인신문을 위하여 감정인신

문에 대하여는 증인신문에 관한 교호신문 방식을 정한 민사소송법 327조가 준용되지 않는다(민소 333조 단서). 감정인신문은 법원이 주도하여 직권으로 신문하되 당사자의 보충적인 신문권을 보장하는 방식으로 진행함은 감정인에게 감정사항을 알리고 감정을 명하기 위한 감정인신문의 경우와 같다.

아. 당사자의 의견진술

법원은 감정인의 의견진술에 관하여 당사자에게 서면이나 말로 의견을 진술할 기회를 주어야 한다(민소 339조 3항). 당사자에게 감정결과 중 모순되거나 명료하지 않은 사항 등에 대하여 의견을 진술할 기회를 부여함으로써 감정절차에 대한 만족도와 감정결과에 대한 신뢰도를 제고하기 위함이다.

법원은 감정인의 의견진술이 있는 경우에 당사자에게 기한을 정하여 그에 관한 의견을 적은 서면을 제출하게 할 수 있다(민소규 101조의3 1항). 통상 감정결과는 일반인이 이해하기 쉽지 않은 전문적인 내용을 담고 있으므로 의견제출기한을 정할 때에는 당사자가 그 내용을 이해, 분석하고 의견을 준비하는 데 어느 정도 시간이 소요될 수 있음을 고려하여야 한다.

자. 보완감정 및 재감정

감정인의 감정결과는 그 감정방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 이를 존중하여야 한다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2010다93790 판결). 또한 법원은 감정인의 감정결과 일부에 오류가 있는 경우에도 그로 인하여 감정사항에 대한 감정결과가 전체적으로 서로 모순되거나 매우 불명료한 것이 아닌 이상, 감정결과 전부를 배척할 것이 아니라 해당되는 일부 부분만을 배척하고 나머지 부분에 관한 감정결과는 증거로 채택하여 사용할 수 있다(대법원 2012. 1. 12. 선고 2009다84608 판결).

그러나 법원이 부여한 전제사실과는 다른 사실을 전제로 감정을 하는 등의 경우에는 그 감정인에게 종전 감정의 보완을 명할 필요가 있는데, 이를

보완감정(보충감정)이라고 한다. 동일한 감정인이 동일한 감정사항에 대하여 서로 모순되거나 매우 불명료한 감정의견을 내놓고 있는 경우에 법원은 감정인에 대하여 감정서의 보완을 명하는 보완감정을 실시하거나 감정인신문 등을 통하여 정확한 감정의견을 밝히도록 하는 등의 적극적인 조치를 강구하여야 하고(대법원 1999. 5. 11. 선고 99다2171 판결), 이는 동일한 감정사항에 대하여 2개 이상의 감정기관이 서로 모순되거나 불명료한 감정의견을 내놓고 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2023. 4. 27. 선고 2022다303216 판결).

종전의 감정절차가 위법하다거나 위와 같은 조치를 취하였음에도 감정의견이 불충분하다거나 신빙성이 의심스러울 경우 또는 여러 사람의 감정의견이 달라 그 채택이 불능인 경우 등에는 재감정의 필요성이 인정될 수 있다. 이와 같이 재감정을 신청할 상당한 사유가 있거나 이에 대한 상대방의 동의가 있음에도, 이미 감정이 실시되었다는 이유만으로 재감정을 채택하지 않는 것은 바람직하지 않다.

따라서 재감정이 신청되면, 법원은 종전 감정절차의 위법성이나 그 감정결과와 오류(또는 오류가능성) 등 신뢰성에 의심이 드는 사유를 구체적으로 제시할 것을 요구하고, 그 사유가 제시되면 우선 감정인신문, 보완감정, 감정관리위원의 의견청취 등을 통하여 그 사유의 존부에 관한 해명조치를 고려하되, 해명조치 없이도 종전 감정절차의 위법성이나 그 감정결과와 오류 등이 명확히 드러나거나, 위와 같은 해명조치를 거쳤음에도 그 감정결과와 신뢰성을 의심할 만한 사유가 해소되지 아니한다면 재감정의 필요성을 높게 보아 재감정신청의 채택을 고려해 볼 수 있다. 제1심에서 감정이 실시되었음에도 항소심에서 동일한 사항에 대하여 재감정이 신청되는 때에는 항소심의 심리구조 및 심급기능을 감안하여 기존 감정결과와 신뢰성을 의심할 만한 구체적 근거와 그 근거의 합리성을 인정할 수 있는 객관적 자료를 바탕으로 재감정의 필요성 여부를 판단함이 바람직하다. 민사소송규칙도 제1심

에서 증거조사가 이루어진 경우라면 특별한 사정이 있어 항소심에서 다시 증거조사를 하는 것이 부득이하다고 인정되는 경우에 한하여 증거신청을 할 수 있다고 규정하고 있다(민소규 127조의4 2항 2호).

재감정을 채택하면 법원은 종전과는 다른 감정인 또는 다른 방법에 의한 새로운 감정절차에 의하여 처리한다.

손해배상사건에서 피고가 원고에 대한 신체감정 결과의 의문점을 지적하며 신체재감정을 신청하자 법원이 이를 받아들여 신체재감정을 촉탁하였으나 원고가 지정 병원이 원거리임을 이유로 재감정에 응하지 아니하여 장기간 신체재감정이 이루어지지 않은 경우, 법원으로서 원고가 주장하는 이유의 상당성 유무를 조사한 다음 그 이유가 상당하다고 판단되면 감정병원을 원고가 입원하고 있는 병원 근처의 병원으로 바꾸어 지정하여 보는 등 증거조사의 방해요인을 적절히 제거하여 재감정이 이루어지도록 하여야 함은 물론 그 래도 재감정이 이루어지지 않는다면 그 증명을 방해하는 측에 적절한 책임을 지우는 것이 타당하다(대법원 1999. 2. 26. 선고 98다51831 판결).

제28장

감정 · 검증 · 사실조회

차. 비디오 등 중계장치 등에 의한 감정인신문

법원은 법정에 직접 출석하기 어려운 특별한 사정이 있는 사람 또는 외국에 거주하는 사람을 감정인으로 신문하는 경우 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 의견을 들어 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하여 신문하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 신문할 수 있다(민소 339조의3 1항). 감정인이 법정에 직접 출석하기 어려운 사정이 있는 경우에도 충실하고 효율적인 감정인신문에 지장이 없도록 하기 위하여 마련된 제도이다. 의료감정을 한 의사가 자신의 근무지인 병원에서 인터넷 화상장치를 통하여 진술하거나 외국에 거주하는 감정인이 외국 현지에서 인터넷 화상장치를 이용하여 진술하는 경우를 예로 들 수 있다. 감정인으로 하여금 자신의 근무지에서 인터넷 화상장치를 통하여 진술하게 하면, 출석에 관한 감정인의 부담이 크게

줄어들고 익숙한 환경에서 기억을 환기하여 더 정확하게 진술할 것이 기대된다.

감정인에게 선서를 시키고 감정을 명하기 위한 최초의 감정인신문은 감정인을 법원에 출석하게 하여 실시하고(이때 선서서나 법원보판금 계좌입금신청서 등의 서류를 제출받는다), 감정서 제출 후 감정인의 보충진술을 듣기 위한 감정인신문은 비디오 등 증계장치 등에 의한 신문으로 실시하면 서류의 제출 등과 관련하여 간소한 업무수행이 가능하다는 장점이 있다.

비디오 등 증계장치 등에 의한 감정인신문을 실시하기로 하는 법원의 결정은 변론(준비)기일에 조서에 기재하여 할 수도 있고 기일 외에서 결정서(전산양식 A1820-1)에 의하여 할 수도 있다.

[조서기재례]

재판장

당사자의 의견을 물어 비디오 등 증계장치에 의한 증계시설(인터넷 화상장치)을 통해 감정인 ○○○에 대한 신문을 실시한다는 결정 고지

비디오 등 증계장치 등에 의한 감정인신문은 감정인을 법정 아닌 곳으로서 비디오 등 증계장치에 의한 증계시설이나 인터넷 화상장치가 설치된 곳에 출석하게 하고, 영상과 음향의 송수신에 의하여 법정 안의 법관, 당사자, 그 밖의 소송관계인과 법정 밖의 감정인이 상대방을 인식할 수 있는 방법으로 한다. 비디오 등 증계장치에 의한 증계시설의 설치, 문서 등의 제시 방법 및 출석에 관하여는 영상기일의 실시에 관한 규정이 준용된다(민소규 104조, 95조의2, 73조의3).

인터넷 화상장치를 이용한 감정인신문에 관하여는 몇 가지 주의할 점이 있다. 인터넷 화상장치를 이용하는 경우 영상기일에 지정된 인터넷 주소에 접속하지 아니한 때에는 불출석한 것으로 본다(감정예규 73조의3 5항). 인터넷 화상장치를 이용한 감정인신문에서도 감정인이 출석의무, 선서의무 등을 이행하

지 아니한 경우 과태료를 부과할 수 있도록 접속할 인터넷 주소를 정확히 기재한 출석요구서를 송달하여야 한다. 신문 과정에서 감정인에 대한 문서 등의 제시가 필요한 경우에 대비하여 미리 감정인과 문서의 제시 방법에 관하여 협의하여 감정인이 필요한 장치를 마련하는 등의 준비를 하도록 조치하여야 한다. 인터넷 화상장치를 이용한 감정인신문 과정에서 선서서를 제출받아야 하는 경우, 감정인에게 대한민국 법원 전자소송포털(<https://ecfs.scourt.go.kr>)에서 선서서(감정인) 양식을 출력하여 두도록 사전에 안내하여야 하고, 신문 과정에서 감정인에게 선서서를 작성하도록 안내한다. 감정인은 감정인신문이 종료한 후 선서서를 법원에 송부하여야 한다.

비디오 등 중계장치 등에 의한 감정인신문은 감정인이 법정에 출석하여 이루어진 감정인신문과 동일한 법적 효력이 있다(민소 339조의3 2항, 327조의2 2항).

카. 감정료 등

감정인에게는 여비·일당·숙박료 및 감정료를 지급하여야 한다. 여비·일당·숙박료는 민사소송비용규칙에 그 한도가 정하여져 있고, 감정료는 ‘감정인등 선정과 감정료 산정기준 등에 관한 예규’에 감정료 기준, 그 예납 및 지급 절차 등이 규정되어 있다. 자세한 내용은 제13장(소송비용) 참조.

위 예규에 따르면 재판장은 필요한 경우에 감정인 후보자로 하여금 감정료의 예상액과 그 산출근거를 기재한 예상감정료산정서를 제출하게 할 수 있고, 예상감정료산정서가 제출된 경우 법원은 이를 감정신청인에게 보여주고 그 적절성에 관한 의견을 제시할 기회를 부여하여야 한다. 재판장은 감정의 대상, 방법, 감정인이 제출한 예상감정료산정서, 감정신청인이 제시한 의견 등을 종합하여 감정료의 예납액을 정한다. 감정료가 정형화되지 않아 감정인에 따라 그 금액이 다양한 건설감정 등에서는 복수의 감정인 후보자들로부터 예상감정료산정서를 제출받고 당사자의 의견을 들은 후 후보자들 중

에서 감정인을 선정하기도 한다.

한편 감정인에게 지급할 여비·일당·숙박료 역시 신청인에게 예납시켰다가 감정인신문 당일에 지급하는 것이 원칙이나, 대부분의 경우 감정인은 여비 등을 감정료에 포함시키고 따로 청구하지 않고 있다. 만일 예상감정료산정서에 위 항목이 포함되어 있지 않은 경우 그 포함 여부를 분명히 하는 것이 좋다.

감정인은 법원에 감정서를 제출할 때 감정료산정서 및 감정료청구서를 함께 제출하여야 한다. 재판장은 감정서가 제출되고 감정결과에 대한 검토 절차가 모두 마쳐진 다음, 감정서 내용의 충실도, 감정서 제출의 지연 여부, 감정인의 감정절차 협조 정도, 감정인이 제출한 감정료산정서의 근거, 감정료에 대한 당사자의 의견 등을 참작하여 감정료를 결정한다. 신체감정 및 진료기록감정의 경우 감정인등 선정과 감정료 산정기준 등에 관한 예규가 개정되어 2025. 1. 1.부터 시행됨에 따라 기본감정료가 상향되었고, 초과감정료 및 사실조회 또는 보완감정의 비용이 신설되었음을 유의할 필요가 있다(감정예규 39조). 위 규정은 위 시행일 이후 감정촉탁기관 및 감정과목별 담당의사를 선정하는 사건부터 적용하므로, 개정 예규 시행일 이전에 감정을 채택했으나 감정촉탁서 반송으로 시행일 이후 감정촉탁기관을 다시 선정하는 사건에도 개정 예규의 의료감정료 규정이 적용된다.

감정인이 감정서를 작성한 후 법원에 감정서를 제출하기 전에 소송 등이 화해, 청구의 포기·인낙, 소의 취하 및 그 밖에 재판에 의하지 아니하고 종결된 경우의 감정료는 위 예규에서 정한 감정료의 2분의 1로 하고, 감정인이 감정서를 작성하기 전에 위와 같은 사유가 발생한 경우에는 감정료를 지급하지 아니한다(다만 여비와 일당은 민사소송비용규칙 소정의 여비 등의 정액으로 함).

3. 감정인의 기피

가. 기피의 사유

감정인이 성실하게 감정할 수 없는 사정이 있는 때에는 당사자가 기피신청을 할 수 있다(민소 336조 본문). 당사자는 법원의 감정인지정결정 자체에 대하여는 불복할 수 없고 오로지 기피신청을 할 수 있을 뿐이다.

법관의 기피사유에 해당할 만한 사유(민소 43조)가 감정인에게 있는 때에는 기피사유에 해당한다고 해석되며, 법관의 기피사유보다는 감정인의 기피사유의 범위가 더 넓다고 설명되고 있다. 감정인의 결격사유(334조 2항)가 있는 경우에도 기피사유가 된다.

나. 기피신청의 방식·시기 등

당사자가 감정인이 감정사항에 관한 진술을 하기 전부터 기피할 이유가 있다는 것을 알고 있었던 때에는 그 진술이 있기 전까지 기피신청을 하여야 하며 그 진술이 이루어진 뒤에는 기피신청을 하지 못한다(민소 336조 단서). 따라서 감정의견을 진술한 후에는 기피사유가 그 후에 발생한 것이거나, 그 후에 당사자가 기피사유 있음을 비로소 안 경우에만 기피신청이 가능하다. 일반적으로 감정인은 서면으로 감정의견을 제출하므로 감정서가 법원에 제출된 이후에는 감정인이 감정의견을 진술한 후에 해당하므로 위와 같은 제한이 따르게 된다.

기피하는 이유와 소명방법은 신청한 날부터 3일 안에 서면으로 제출하여야 한다(민소규 102조 2항). 감정인의 편향성이나 불공정성 등에 관한 의혹을 제기하면서 감정인의 교체를 요구하거나 기피신청을 하는 경우가 있는데, 막연한 의혹이나 추상적인 불공정성 주장만으로는 부족하고 기피사유를 소명할 수 있는 구체적 사실과 자료가 제출되어야 한다. 기일에 출석하여 기피신청을 하는 때에는 그에 관한 사항은 조서에 기재될 것이므로 말로도 할 수 있다(민소 161조). 여기서 기일은 감정인에게 선서를 시킨 후 감정을 명하

기 위한 감정인신문기일이나 감정의견을 진술하기 위하여 별도로 지정된 감정인신문기일(다만 서면으로 감정의견을 제출하고 말로써 보충하는 경우에는 앞서 본 바와 같은 제한이 따른다) 등을 모두 포함한다.

기피신청은 수소법원·수명법관 또는 수탁판사에게 하여야 하는데(민소 337조 1항), 그 구분은 해당 감정인의 지정결정을 누가 하였느냐에 따른다. 다만 수명법관이나 수탁판사가 감정인을 지정한 경우라도 감정이 종료되어 기록이 수소법원에 있는 때에는 수소법원에 신청하여야 한다.

기피신청은 문건으로 전산입력하므로(인지액·편철방법예규 3조), 기록도 따로 만들지 않고 본 소송기록에 가철한다.

기피하는 사유는 소명하여야 하는데(민소 337조 2항), 만약 감정의견의 진술이 있는 후에 기피신청을 할 때에는 기피원인이 그 후에 발생하였다는 당사자가 그 후에 기피원인 있음을 알게 되었다는 점까지 소명하여야 함은 물론이다.

다. 기피신청에 대한 재판

기피신청에 대한 재판은 결정의 형식으로 하며 당사자의 심문 여부, 감정인의 의견진술 기회 부여 여부 등은 법원(또는 수명법관·수탁판사)의 재량에 속한다. 재판의 주문·이유 등의 방식은 법관기피의 경우에 준한다.

기피신청이 이유 있다고 하는 결정이 있게 되면 감정인은 그 자격을 상실하게 되므로 더 이상 감정을 할 수 없고, 감정의견의 진술이 있는 후라면 그 감정의견은 효력이 없게 된다.

기피하는 데 정당한 이유가 있다고 한 결정에 대하여는 불복할 수 없고, 이유가 없다고 한 결정에 대하여만 즉시항고를 할 수 있다(민소 337조 3항). 후자의 결정이 수명법관·수탁판사의 재판인 경우에는 우선 수소법원에 이의신청(441조)을 하고(다만 그 기간은 즉시항고 기간 내), 그 이의가 기각된 경우에 한하여 그 결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있다.

4. 감정의 촉탁

법원은 필요하다고 인정하는 경우에는 공공기관·학교, 그 밖에 상당한 설비가 있는 단체 또는 외국의 공공기관에 감정을 촉탁할 수 있는데, 이 경우에는 선서에 관한 규정을 적용하지 아니한다(민소 341조 1항). 감정촉탁의 경우에는 이와 같이 선서의무 등이 면제됨에 비추어 권위 있는 기관에 의하여 그 공정성·진실성 및 전문성이 담보되어야 한다(대법원 1982. 8. 24. 선고 82다카317 판결).

[전산양식 A1783] 신체감정촉탁서

제28장

감정 · 검증 · 사실조회

○ ○ 법 원
신체 감정 촉탁서

수 신 병원장
제 목 신체감정촉탁

이 법원 2000가단1000

사건에 관한 아래 사람의 신체 감정에 대하여 별지 기재와 같이 귀 병원 소속 의사를 지정하여 촉탁하오니 그 감정결과를 20〇〇. 〇. 〇. 까지 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.

(사본 2부를 첨부할 것)

아 래

1. 감정 대상자 :
2. 감 정 사 항 : 별지와 같음
3. 첨 부 서 류 : 감정대상자를 치료한 병원의 진료기록(진단서, 응급실 기록, X-RAY·MRI·CT 등 방사선필름 및 판독지, 치료소견서등) 사본 1부.
4. 신청인 연락처 :
5. 상대방 연락처 :

2000. 0. 0.
판 사

하고 이에 따라 동 병원장이 그 소속의사를 감정인으로 지정하여 그 의사가 자기명의로 작성·송부하여 온 감정서나, 법원이 위 감정촉탁병원장에게 사실조회를 하여 동 병원장 명의로 송부되어 온 위 감정의사가 작성한 병원장의 회보서는 감정촉탁결과라고 볼 것이므로 증거로서 사실인정의 자료로 할 수 있다(대법원 1986. 9. 23. 선고 85다카1923 판결).

감정촉탁서는 재판장 이름으로 작성하여 송부한다(민소 139조 2항). 법원은 전자소송시스템에 감정 기관으로 등록된 기관에 대하여는 감정을 전자적인 방법으로 촉탁할 수 있다(민전규 37조 3항, 민전예규 85조 1항). 법원이 감정 기관으로 등록되지 않은 기관에 대하여 감정을 촉탁할 때에는 촉탁을 받은 기관이 감정서를 전자적인 방법으로 제출할 수 있도록 전자소송인증번호를 부여한다(민전예규 85조 2항).

감정촉탁에 의하여 감정을 한 기관은 비용과 감정료를 청구할 수 있는바, 그중 비용은 감정시행단계(신체감정의 경우 병원에서의 입원·검진 등)에서 당사자가 직접 지출하는 것이 보통이고(따라서 법원에 대하여는 청구하지 않는다), 감정료는 위 기관의 이름으로 청구하는 것이 아니라 직접 감정사무를 담당하는 그 기관 소속 특정인 개인의 이름으로 청구하는 것이 보통이다(그리고 감정결과와 송부에 있어서도 그 개인 명의의 감정서를 첨부하여 송부하는 형식을 밟는다). 이러한 경우 예납받은 감정료는 그 청구인 개인 앞으로 지급하여도 무방하다.

감정을 촉탁한 경우 그 후에 제출된 감정서에 분명치 아니하거나 불비된 점이 있는 등 법원이 필요하다고 인정한 때에는 감정을 한 단체 등이 지정한 자(대부분 실제로 감정을 수행한 사람이 될 것이다)로 하여금 감정서를 설명하게 할 수 있다(민소 341조 2항). 직접주의의 원칙상 이러한 설명은 변론(준비)기일에 출석하여 시행함이 타당하나, 기일에 출석시키지 아니하고 법정 이외의 장소에서 설명하게 하여도 무방하고 다만 이 경우에는 심문조서를 작성하여야 한다. 감정서의 설명을 하게 할 때에는 당사자를 참여하게 하여

야 하고(민소규 103조 1항), 그 설명의 요지를 조서에 기재하여(2항), 감정서의 내용을 보충하는 자료가 되도록 하여야 한다. 감정의 설명자는 감정서의 기재내용을 보충설명하는 사람에 불과하여 증인이나 감정인의 지위를 가지는 것은 아니므로 선서시킬 필요가 없다. 이 경우의 조서용지는 증인신문조서 양식을 적절히 변형하여(예컨대 제목을 ‘감정서 설명조서’로 하고 선서에 관한 인쇄문구를 지우는 등으로) 사용한다. 이 설명은 독립한 증거방법이 아니므로 증인등목록에 따로 기재할 필요가 없고 그 조서의 장수만을 해당 감정촉탁란의 ‘장수’란에 병기해 주면 된다.

감정을 한 단체 등이 지정한 자로 하여금 감정서를 설명하게 하는 경우 법원은 비디오 등 증계장치에 의한 증계시설을 통하여 설명하게 하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 설명하게 할 수 있고, 그 요건, 절차, 방법 및 조서 작성 등에 관하여는 비디오 등 증계장치 등에 의한 감정인신문에 관한 규정이 준용된다(민소 341조 3항, 339조의3, 민소규 103조의2 2항, 1항 단서, 95조 2항 내지 4항).

[조서기재례]

재판장

당사자의 의견을 물어 비디오 등 증계장치에 의한 증계시설(인터넷 화상장치)을 통해 ○○연구소 담당연구원 ○○○로부터 감정서 설명을 듣는다는 결정 고지

실무에서는 감정을 한 단체 등에 대하여 서면에 의한 설명 내지 보완을 요구하는 경우도 있는데, 이때 발송하는 서면의 형식은 ‘사실조회서’가 아니라 감정보완촉탁[전산양식 A1788]으로 하여야 한다.

[전산양식 A1788] 감정보완촉탁

○ ○ 법 원

20○○. ○. ○.

수 신

제 목 감정결과 보완 촉탁

당원 20 가 사건에 관하여 20○○. ○. ○. 자 감정인의 감정결과 중 별지 사항에 대한 보완을 요청하오니 회보하여 주시기 바랍니다.

판 사 ○ ○ ○ ㉠

※ 이 법원에 제출하는 서면에는 사건번호(20 가)를 반드시 기재하여 주시기 바랍니다.

※ 문의사항 연락처 : ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○
전화 : ○○○ — ○○○○
팩스 : ○○○ — ○○○○ e-mail :
주소 :

한편 당사자도 그의 증거신청권에 기하여 감정에 관여한 자의 의견진술 (수동적으로 설명을 듣는 범위를 넘어 능동적으로 질문을 하는 것)을 구할 수 있음은 물론인데, 법원이 그 신청을 받아들일 경우 그 신문사항이 감정내용에 관한 것이라면 감정인신문에 준하여, 감정을 함에 즈음하여 구체적으로 체험한 사실에 관한 것이라면 감정증인신문에 준하여 각각 선서를 시키고 신문한다. 이 경우는 각각 독립한 증거방법이 되므로 증인등목록에 따로 기재 하여야 한다.

감정촉탁을 하였는데도 장기간 회신이 없는 경우에 무한정 회신을 기다리는 것은 소송촉진의 측면에서 바람직하지 아니하므로 일정기간이 지나도록 회신이 없으면 재판부가 독촉을 하거나 감정관리위원으로 하여금 감정절차

제28장
감정 · 검증 · 사실조회

의 진행상황을 보고하게 하는 등으로 소송촉진을 기하여야 한다.

5. 감정결과의 채부

감정인의 의견진술이 있으면 법원은 감정의 결과를 법정에 현출시켜 당사자에게 변론의 기회를 주어야 한다. 감정의 결과가 법정에 현출된 이상 당사자가 원용한다는 진술을 하지 않아도 증거자료로 사용할 수 있다(대법원 1976. 6. 22. 선고 75다2227 판결). 실무에서는 감정결과에 대한 법원의 판단을 받기 위하여(대법원 1974. 10. 8. 선고 73다1879 판결 참조), 감정결과가 유리한 당사자 측에서 이를 원용한다는 진술을 하는 것이 보통이다.

감정의 결과를 현실적으로 증거로 채용하느냐는 다른 증거와 마찬가지로 법관의 자유심증에 의한다(민소 202조). 그러나 감정인의 감정결과는 그 감정방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 이를 존중하여야 한다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2010다93790 판결). 감정결과는 법관이 감정인의 특별한 지식과 경험을 이용하는 데 불과하므로, 예를 들면 감정결과에 의료과오의 유무에 관한 견해가 포함되어 있어도 법원은 그 견해에 기속되지 않는다(대법원 1998. 7. 24. 선고 98다12270 판결). 동일 사항에 대한 수개의 상반된 감정결과가 있는 경우 법원은 각 감정결과의 감정방법이 적법한지 여부를 심리·조사하여야 하는데(대법원 1992. 3. 27. 선고 91다34561 판결), 그중 어느 것에 의하여 사실인정을 하는가는 법원의 자유심증의 범위에 속하는 것으로서 논리와 경험칙에 위반되지 아니하는 한 적법하다(대법원 1997. 12. 12. 선고 97다36507 판결). 다만 이 경우 법원이 그 감정결과를 증거로 채용하여 사실을 인정하기 위해서는 다른 증거자료가 뒷받침되지 않는 한, 각 감정기관에 대하여 감정서의 보완을 명하거나 증인신문이나 사실조회 등의 방법을 통하여 정확한 감정의견을 밝히도록 하는 등 적극적인 조치를 강구하여야 하고, 이러한 법리는 전문적인 학식과 경험이 있는 사람이 작성한 감정의견이 기재된 서면이 서증의 방법으로 제출된 경

우에 사실심 법원이 이를 채택하여 사실인정의 자료로 삼으려 할 때에도 마찬가지로 적용될 수 있다(대법원 2023. 4. 27. 선고 2022다303216 판결). 법원은 감정인의 감정결과 일부에 오류가 있는 경우에도 그로 인하여 감정사항에 대한 감정결과가 전체적으로 서로 모순되거나 매우 불명료한 것이 아닌 이상, 감정결과 전부를 배척하여야 할 것이 아니라 그 해당되는 일부 부분만을 배척하고 나머지 부분에 관한 감정결과는 증거로 채택하여 사용할 수 있다(대법원 2012. 1. 12. 선고 2009다84608 판결). 당사자의 약정에 의하여 지명된 감정인의 감정의견에 따라 하자보수비용 등을 정하기로 하는 경우가 있는데, 이는 증거계약의 일종인 중재감정계약으로서, 당사자의 약정 취지에 어긋나는 감정이 이루어졌다든가, 그 감정의견이 신빙성이 없다고 판단되는 등의 특별한 사정이 없는 한 당사자는 그 감정결과에 따라야 한다(대법원 2014. 5. 29. 선고 2012다54126 판결).

6. 감정증인

감정증인이란 특별한 학식·경험을 가졌기 때문에 알게 된 과거의 구체적 사실에 대하여 진술하는 증인을 말한다. 사실을 알게 되는 과정에서 특별한 학식과 경험을 이용하였다는 것일 뿐 어디까지나 사실에 관한 진술을 하는 자이므로 증인의 일종이며 감정인이 아니다. 따라서 교호신문 방식(민소 327 조) 등 증인신문에 관한 규정에 의하여 한다. 감정증인신문에 대해서는 원칙적으로 녹음이 필요한 경우에 해당한다고 보아 그 전부를 녹음한다(속기·녹음예규 9조의2 본문).

한편 법원의 명에 따라 감정을 행한 감정인에 대하여 설명을 구하거나 신문하는 경우에는, 단순한 감정의 연장에 불과하여 감정의견의 진술에 포함될 수 있는 경우와 감정을 하는 과정에서 구체적으로 체험한 사실을 진술하는 감정증인으로 보아야 하는 경우의 두 가지가 있다.

제2절 검 증

1. 의 의

검증이란 법관이 직접 자기의 오관(五官)의 작용에 의하여 사물의 성상이나 현상을 보고, 듣고, 느낀 인식을 증거자료로 하는 증거조사방법이다. 검증의 대상이 되는 사물을 검증물이라고 한다. 검증은 자동차사고의 현장, 각종 공사장·기계의 상황, 토지의 경계상황 등과 같이 주로 시각에 의하여 인식할 수 있는 것에 많이 활용되나, 소음, 가스의 냄새 등 청각 또는 후각에 의하여 인식할 수 있는 것도 검증의 대상이 된다.

서증과 검증을 비교하여 보면, 서증은 문자나 부호에 의하여 기재된 문서의 내용을 증거자료로 쓰는 것이지만, 검증은 검증물의 존재사실이나 성상·현상 등 주로 외형 자체에 대한 인식을 증거자료로 쓰는 점에서 차이가 있다.

서증의 진정성립 인정을 위한 필적 또는 인영의 대조(민소 359조)는 육안에 의한 판별이 가능한 범위 내에서는 검증절차에 의하여야 한다는 점은 앞에서 설명하였다.

2. 절 차

가. 증거의 채부결정

검증은 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 증거결정을 함으로써 시행한다. 당사자가 검증을 신청하는 때에는 검증의 목적(검증물)을 특정하여 표시하여야 하고(민소 364조), 증명할 사실 및 검증과 증명할 사실의 관계를 구체적으로 명시하여야 한다(289조, 민소규 74조).

서면공방과정에서 현장검증 등의 필요성이 부각된 때에는 검증신청을 유도하여 적시에 검증을 실시하여야 하고, 검증물과 관련하여 증인신문, 당사자신문을 하거나 검증실시에 감정인을 참여시킬 필요가 있을 때에는 그에

필요한 증거신청도 동시에 하도록 유도하는 것이 좋다.

수소법원은 필요에 따라 법원 밖에서 검증을 하게 하기 위하여 수명법관이나 수탁판사에게 검증을 수권할 때(민소 297조) 수명법관 등에게 검증과 동시에 감정이나 증인신문까지 수권할 수 있는데, 이러한 수권이 없더라도 수명법관 등은 검증에 필요하다고 인정할 때에는 감정을 명하거나 증인을 신문할 수 있다(365조).

제28장

감정 · 검증 · 사실조회

나. 비용 예납

변론(준비)기일에 또는 법원의 청사 내에서 검증을 행하는 경우(예컨대 문서의 인영대조 검증 등)에는 특별한 비용이 필요하지 않을 것이나, 현장에 나가서 검증을 행하는 경우에는 법관 및 법원사무관등의 여비·숙박료에 해당하는 비용이 필요하게 되는바, 이 비용은 법원의 예납명령(민소규 77조)에 따라 신청 당사자가 예납하여야 한다. 직권으로 검증을 할 경우에는 그 검증으로 이익을 받을 당사자에게 예납을 명하고, 이익을 받을 당사자가 분명하지 아니하면 원고에게 예납을 명한다(19조).

여비·숙박료의 기준에 관하여는 제13장(소송비용) 참조.

다. 기일의 지정 및 출석요구

검증기일은 재판장 또는 수명법관 등이 정하고, 변론(준비)기일에 검증을 할 때에는 그 기일은 변론(준비)기일인 동시에 증거조사기일이 된다. 변론(준비)기일에서 기일을 지정하는 경우에는 ‘고지된 다음 기일’란 바로 아래에 “검증기일 2025. 2. 14. 11:00”와 같이 기재하고 증인등목록의 ‘증거조사’란에 “2025. 2. 14. 11:00”와 같이 기재한다. 기일 전에 기일지정을 하는 경우에는 증인등목록의 ‘기일’란에 “기일외”라고 기재한다.

검증기일에는 당사자에게 출석을 요구하여 참여의 기회를 주어야 하며, 같은 기일에 증인신문 또는 감정인신문을 하기로 한 때에는 이들에게도 출

석을 요구하여야 한다. 법원 밖에서 검증을 행하는 경우에는 검증의 일시·장소를 특히 명확하게 하여야 한다.

라. 검증목적물의 제출

현장검증 기타 법원이 검증목적물의 소재지에 출장하여 검증을 실시하는 경우 이외에는 검증을 실시하기 위하여 검증목적물이 법원에 제출되어야 하는데, 그 방법에 관하여는 서증에 관한 규정이 준용된다(민소 366조 1항). 따라서 신청인이 소지하고 있는 물건은 이를 직접 제출하고(343조 전단), 상대방 또는 제3자가 소지하고 있는 물건은 제출명령신청(후단) 또는 송부촉탁신청(352조)에 의하게 된다. 제3자에 대하여 검증목적물의 제출을 명하는 경우에는 제3자 또는 그가 지정하는 자를 심문하여야 한다(366조, 347조 3항).

제출된 검증목적물에는 서증에 있어서와 마찬가지로 방법으로 부호와 번호를 붙이되 서증과의 구별을 위하여 그 앞에 “검”자를 표시한다(민소규 117조). 따라서 원고가 제출한 것은 “검갑 제○호증”, 피고가 제출한 것은 “검을 제○호증”이라고 표시한다. 이 부호 및 번호는 서증의 경우와 달리 증거목록에 독립한 증거방법으로 표시되지 않으며, 해당 검증란에 부기되는 데 불과하다. 이 부호와 번호는 검증목적물이 다수인 경우 조서 및 판결서 작성에 있어서 특히 유용하게 사용된다.

법원은 필요하다고 인정하는 때에는 제출되거나 보내온 검증목적물을 보관할 수 있는데(민소 366조 1항, 353조), 이 경우 제출자 또는 송부자가 요구하는 때에는 법원사무관등은 그 물건의 보관증을 교부하여야 하며, 한편 검증을 마친 후에도 법원은 검증목적물의 재제출을 명할 수 있다(민소규 118조, 105조 5항, 111조 2항).

마. 검증실시의 준비

(1) 기록의 조사와 검증목적의 파악

법원 밖 검증의 경우 법원사무관등은 당사자 및 관계인의 출석 요구, 비용의 예납 등을 미리 점검하여야 하고, 기록을 통하여 사건의 개요와 검증의 목적(검증에 의하여 증명할 사실)을 파악하여야 하며, 기록에서 필요한 도면(지적도·현황도 등)을 복사하는 등 준비를 하여야 한다.

(2) 협조의뢰문의 발송 등

검증에 제3자의 협력이 필요한 경우에는 재판장등 명의의 검증협조의뢰 [전산양식 A1781] 공문을 발송하는 것이 관례인데, 협조의뢰문의 발송은 제3자로 하여금 미리 검증에 대비할 여유를 준다는 점에서 실익이 있다. 소송당사자나 제3자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 부동산에의 출입 등의 검증절차를 수인할 의무가 있으며, 법원은 검증을 위하여 필요한 경우에는 남의 토지·주거 등의 시설물 안에 들어갈 수 있고, 저항을 받은 때에는 경찰공무원에게 원조를 요청할 수 있다(민소 366조 3항, 342조 1항).

당사자가 검증물을 제시하지 않거나 출석요구에 불응한 때에는 법원은 검증물의 존재·성상에 대한 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있고(민소 366조 1항, 349조), 당사자가 상대방의 사용을 방해할 목적으로 제출의무가 있는 검증목적물을 훼손하여 버리거나 이를 사용할 수 없게 한 때에도 이와 같다(366조 1항, 350조). 제3자가 정당한 사유 없이 법원의 검증목적물 제출명령에 응하지 아니한 때에는 법원은 결정으로 200만 원 이하의 과태료에 처할 수 있으며, 이 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(366조 2항).

(3) 준비물

① 해당 사건의 기록

② 조서용지, 증인·감정인에 대한 선서서, 증인에게 지급할 일당 등 청구서와 영수증

증인에게 여비를 지급할 사유에 해당하는 경우, 예납된 여비를 미리 찾아

서 청구서 및 영수증과 함께 지참하였다가 신문종료 후 현장에서 현금으로 지급하고, 위 청구서 및 영수증에 날인을 받아야 한다.

③ 현장약도·필기구·백지·인주·사진기·자·분도기(分度器)·나침반 등

바. 검증의 실시

(1) 참여사무관등의 임무

검증의 주재는 법관이 하고, 법원사무관등은 증거조사절차가 적법하게 시행되었다는 것을 조서의 작성에 의하여 기록·공증하는 것을 그 임무로 한다.

법원사무관등은 법관이 주재하는 검증절차에 적극적으로 참여하여 모든 절차가 원활히 진행되도록 필요한 모든 노력을 하여야 하고, 검증조서의 작성을 위하여 필요한 모든 자료를 조사·기록하여야 한다. 검증물 자체는 물론 주위의 상황, 계쟁물의 위치, 건물의 구조·사용현황·파손의 정도 등 필요하다고 인정되는 것은 모두 기록하여야 한다. 또한 현장에서 당사자의 주장이나 설명이 있으면 그 요지를 기재함으로써 후일 조서작성에 필요하고도 충분한 자료를 수집하여야 한다.

(2) 검증현장에서의 화해

검증 종료 전에 화해가 성립한 경우에는 검증조서를 작성할 필요 없이 화해조서를 작성하면 된다. 그러나 검증 종료 후에 화해가 성립한 경우에는 검증조서를 작성해 두어야 한다. 준재심 청구가 들어왔을 경우에 실익이 있기 때문이다. 수명법관도 화해를 시킬 수 있다.

3. 검증조서

가. 서 설

검증조서는 검증에 참여한 법원사무관등이 검증의 경과 및 결과를 명백히 하기 위하여 작성하는 조서로서, 그 기재사항에 관하여는 변론조서에 관한 규정이 준용된다(민소 160조, 153조, 154조).

[전산양식 A1663] 검증조서

○ ○ 법 원
검 증 조 서

사 건 20 가 기 일 20○○. ○. ○. :
판 사 장 소
법원사무관 공개여부 공 개

사건과 당사자의 이름을 부름

원 고
피 고

출석
출석

1. 검증의 목적물
1. 검증목적
1. 검증 장소의 위치
1. 현장에서의 당사자의 주장
 - 가. 원고의 주장
 - 나. 피고의 주장
1. 검증결과

도면 매 및 사진 매 각 첨부

이 검증은 :00 시작하여 :00 종료하였다.

법원사무관 ㉠
재판장 판사 ㉠

제28장

감정 · 검증 · 사실조회

검증이 변론(준비)기일 외에서 시행될 경우에는 먼저 기본조서인 기일조서 [전산양식 A1662]를 작성하고, 이에 “별지 조서와 같이 검증 시행”이라고 기재한 후, 별도의 검증조서[전산양식 A1663]를 작성·첨부하고 간인한다. 검증이 변론준비기일에서 시행될 경우에는 기본조서인 통상의 변론준비기일조서 [전산양식 A1650]에 위와 같이 기재한 후 검증조서를 작성 첨부하고 간인한다. 이때는 검증조서의 제목 옆에 “(○차 변론준비기일조서의 일부)”라고 부기해야 한다.

한 기일에 검증, 감정인 및 증인신문이 시행된 때에는 기본조서에 “별지

조서와 같이 검증 시행, 감정인 및 증인 신문”이라 기재하고 해당 각 조서를 작성·첨부한다.

나. 형식적 기재사항

(1) 사건의 표시

수소법원 또는 수명법관이 검증을 시행하는 경우에는 해당 사건번호와 사건명을 기재한다. 수탁판사가 검증을 시행하는 경우에는 공조사건의 번호 및 사건명(예: 2025러14 증거조사촉탁)을 기재하고, 절차의 요지 등 난의 모두에 촉탁법원의 사건번호와 사건명을 기재한다(예: 2025가합101 건물철거등).

(2) 기일, 재판부, 당사자의 출석 상황 등

통상의 변론조서 기재 방식과 같다. 검증 현장에서 신문할 증인·감정인의 출석 상황은 기본조서(기일조서)에만 기입하면 충분하고, 검증조서에는 기재하지 않는다. 검증 현장에서 검증 시행 도중에 지시설명 등을 한 사람의 성명 등은 실질적 기재사항에만 기재할 뿐 여기에는 기재하지 않는다.

(3) 장소 및 공개 여부

검증이 실시된 장소가 토지나 건물이면 지번으로 표시하고, 해상인 경우에는 “○○항구로부터 ○○방면 ○km 해상”이라고 표시하고, 기계인 경우에는 그 기계의 소재지를 표시한다. 산림 등 광범위한 토지가 검증장소인 경우에는 그 전부의 지번을 표시할 필요는 없고 사건을 호명하였던 장소의 지번만 표시하면 된다.

공개 여부는 “공개”로 한다.

(4) 법관, 법원사무관등의 성명 및 기명날인

변론조서의 기재방식과 같다.

(5) 검증의 실시시간

검증의 개시시각과 종료시각은 반드시 기재하여야 하는 것은 아니나 실무상 기재하는 것이 관례이다. 실질적 기재사항의 말미에 “이 검증은 14 : 00에

시작하여 15 : 00에 종료하였다.”라고 기재함이 보통이다.

다. 실질적 기재사항

검증조서의 실질적 기재사항으로는 ① 검증의 목적물, ② 검증 목적, ③ 검증장소의 위치, ④ 검증현장에서의 당사자의 주장이나 설명, ⑤ 검증의 결과 등의 순서로 기재하는 것이 보통이다. 이 중 ③, ④는 현장검증의 경우에만 해당되는 것이고 ④는 실제로 그러한 주장이나 지시설명이 행하여진 때에만 기재하며, 별도의 항목을 두지 않고 다른 사항을 기재하는 도중에 군데 군데 삽입하는 것이 편리한 때도 많으며, 내용상으로는 검증결과에 포함시켜야 할 사항인데 검증결과 항에 기재하지 않고 ③ 검증장소의 위치 다음에 현장의 상황이라는 항을 별도로 두어 기재하기도 한다.

이 중에서 가장 중요한 것은 민사소송법 154조 3호에서 필수적 기재사항으로 규정하고 있는 ⑤ 검증의 결과이며, 나머지 사항은 이 검증결과의 내용을 설명하기 위한 기초사실 내지 전제사실이라 할 수 있다. 검증조서에 기재하는 검증의 결과는 검증의 주체인 법관이 인식한 내용을 그의 지시에 따라 법원사무관등이 기재하는 것이다.

(1) 검증의 목적물

검증의 목적물은 그 기재 자체로서 검증물이 특정될 수 있도록 가능한 한 명확히 기재하여야 한다. 토지의 검증일 경우에는 검증목적물이 검증장소와 일치하는 수가 있으나, 이때에도 검증의 목적물이라고 표시하여야 하고 검증장소라고 표시하여서는 안 된다(검증의 장소는 ‘형식적 기재사항’란에 이미 표시되어 있다).

① 토지: 원고 소유의 서울 ○○구 ○○동 158-1 및 피고 소유의 같은 동 159 각 대지

② 교통사고 현장: 서울 ○○구 ○○동 100 앞 교차로 부근

③ 기계: 서울 ○○구 ○○동 100 피고 소유의 공장 내(별지 제1도면 표시

‘가’호)에 있는 인쇄기 1대

교통사고 현장 상황의 검증처럼 검증의 목적물이라고 표시하기가 부적합한 경우에는 “검증의 대상”이라고 기재하는 것이 좋다.

(2) 검증 목적(검증에 의하여 명백히 할 사항)

검증조서에 기재하여야 할 검증의 목적은 검증에 의해 명백히 할 사항을 말한다. 검증의 목적은 대체로 검증신청서에 기재된 검증의 목적과 일치하는 때가 많으나, 당사자가 검증신청서에 권리 또는 주장사실 그 자체를 검증의 목적으로 기재하여 오는 경우(예컨대 A, B점을 잇는 선이 원고 소유 토지의 경계선인 사실을 밝히기 위함, 피고에게 과실이 있음을 밝히기 위함, 건물이 노후상태에 있다는 사실을 밝히기 위함 등)에는 이를 그대로 옮겨 쓰는 것은 피하여야 한다.

검증의 목적은 신청인이 증명하고자 하는 사실 또는 상태의 유무 내지 여부를 객관적 입장에서 본 문제점으로 구성하여 표현하여야 한다. 아래의 예시와 같은 문구를 만든 다음 “...을 확인함에 있다.”라는 문장을 구성하여 기재한다.

① 토지: 피고가 원고 소유의 위 대지 중 일부를 점유하고 있는지 여부, 점유하고 있다면 그 위치 및 면적

② 건물: 피고들이 위 건물을 일부씩 점유 사용하고 있는지 여부, 점유 사용하고 있다면 그 위치 및 면적

③ 기계: 위 인쇄기의 작동순서 및 안전시설의 유무

④ 교통사고: 위 도로 부근의 상황, 횡단보도의 설치 유무, 지하철공사로 일방통행으로 되었는지 여부

⑤ 유익비: 위 건물에 관하여 피고가 시행하였다고 주장하는 개량공사의 내용과 현황

다만 감정을 병행하는 경우에는 감정을 명할 사항을 분리하여 “... 여부를 확인하고 ...에 관하여 감정인에게 감정을 명함에 있다.”라고 기재하기도 한다.

(3) 검증장소의 위치

검증장소는 ‘형식적 기재사항’란에 지번이 표시되어 있으나 지번만으로는 위치가 불분명하므로, 누구든지 검증조서만 보면 현장을 찾아갈 수 있도록 구체적인 위치를 설명하여야 한다. 대개는 자세한 현장위치도를 작성하여(공로의 주요 표적물을 기점으로 하여 현장에 이르는 길을 표시하되 갈라지는 길의 상점, 나무 등 표적물과 방향, 거리를 명시한다) 그 도면을 인용해 가면서 설명하는 것이 편리하다.

도면이 완벽한 때에는 본문에서는 “별지 현장위치도의 사선 표시 부분과 같다.”로만 기재하여도 무방하나, 도면에 대한 간단한 보충설명을 하는 것이 필요한 경우가 많다.

[기재례]

이 곳 현장은 ○○, ○○간 도로(편도 3차선)의 ○○기점 약 500m 지점에 위치한 별지 제1도면 표시 ○○슈퍼 옆으로 난 골목을 따라 약 400m 걸어 들어간 같은 도면 표시 사선 부분에 위치하고 있다.

○○동 네거리에서 ○○시로 가는 도로(편도 1차선)변의 별지 제1도면 표시 위치에 ○○농장 입구가 있고, 거기서 그 맞은편으로 난 비포장도로로 좌회전하여 약 2km 들어가면 ○○마을 입구라는 표시석이 서 있으며, 그 곳에서 서쪽으로 약 300m 거리에 야트막한 야산이 보이는데, 그 야산의 남동쪽 기슭에 해당하는 같은 도면 표시 적색 사선 부분에 이 곳 현장이 위치하고 있다.

(4) 현장에서의 당사자의 주장 또는 현장에 있는 자의 설명

당사자를 포함하여 검증현장에 있는 자로부터 검증물 자체 또는 검증물과 증명할 사항 내지는 주장사실과의 관계에 관하여 설명을 들을 필요가 있는 경우가 많다. 설명이라 하여도 변론에 나타난 사실을 뒷받침할 증거(검증물)를 지적함으로써 충분한 경우(예컨대 인도청구소송에 있어서 건물의 점유 사용 부분의 지적)도 있고, 교통사고 현장의 검증과 같이 현장에서의 실제 교통사고 지점을 지적할 경우는 물론 사고관계자의 위치, 사고발생 전후의 경과 등

에 관하여 구체적인 설명을 보낼 필요가 있는 경우도 있어 구체적인 경우에 그 형태를 달리한다. 그 어느 경우라도 이러한 설명이 있었을 때에는 검증결과와 기재를 쉽게 이해할 수 있도록 필요한 정도로 항을 달리하여 기재해주는 것이 좋다.

뿐만 아니라 당사자는 검증현장에서 종전 준비서면 또는 변론(준비)기일에서의 주장을 현장의 어떤 상황과 관련시켜서 더욱 구체화하거나 발전시켜서 적극적으로 주장하고 상대방은 이를 반박하는 등 공방이 벌어지는 경우가 많은데, 이러한 양쪽 당사자의 주장 역시 검증결과와의 이해에 도움이 될 뿐더러 소송자체의 쟁점 파악에도 도움이 되므로 역시 항을 달리하여 기재해 주는 것이 좋다.

다만 순수한 증거조사기일로서의 검증기일은 변론(준비)기일이 아니므로 원칙적으로 서면공방절차에서 하지 아니한 주장을 하거나 종전 주장을 바꾸는 주장은 할 수 없다. 그러나 막상 현장에 도착해 본 결과 종전 주장이 잘못되었음을 알게 된 당사자, 특히 소송대리인에게 새로운 주장을 못하게 하는 것은 사실상 불합리하므로 검증결과를 이해하는 데 도움이 되는 범위 내에서 간략하게 기재해 주는 것이 실무이다. 이 경우에도 변론에서 다시 그러한 주장을 하지 않으면 소송상 주장으로서의 효력이 없게 된다. 다만 변론(준비)기일에서 법원이 석명권을 행사하여 주장의 축구를 하여야 할 사항에 속한다.

법원이 상당하다고 인정하는 경우에는 수명법관이나 수탁판사에 의한 증인신문이 가능하므로, 법원 밖에서 검증을 하면서 동시에 목격증인을 신문할 필요가 있는 경우에는 검증현장에서 수명법관이 신문할 수 있을 것이다.

다만 위 두 경우 다음 변론에서 그러한 주장과 증거조사의 결과를 변론에 상정하여야 한다.

(5) 검증의 결과

검증의 결과는 검증조서의 근간이 되는 가장 중요한 실질적 기재사항이다. 검증은 법관이 오관의 작용에 의하여 증거방법인 검증물로부터 직접 증

거자료를 얻는 행위이고 이 행위의 결과로 인식된 것이 검증의 결과이다. 검증의 결과를 아래와 같은 방식으로 조서에 기재한다.

(가) 일반적 사항

① 사실인식의 결과는 간결하고 요령 있게 기재하여야 하지만, 어떻게 하여 그러한 결론 또는 사실인식에 도달하였는지의 이유를 기재한다. 예컨대 중기사고 현장의 검증에서 ㉠지점에서 사고현장인 ㉡지점이 보이지 않을 경우에 “㉠지점에서 사고현장인 ㉡지점 사이에는 높이 〇m 길이 〇m의 담(건축물)이 있기 때문에 이 담에 가려 ㉠지점에서는 ㉡지점이 보이지 않는다.”라는 식으로 기재한다.

② 검증에는 일정한 목적이 있으므로, 그 목적에 대응하여 필요하고도 충분한 한도로 사항별로 항목을 분류하여 기재한다.

③ 검증의 결과를 기재할 때, 목적물의 위치와 현장의 상황의 기재가 필요한 경우가 있고(예: 교통사고·공유물분할·토지경계확정 등), 기점을 설정하는 것이 필요한 경우(예: 교통사고·토지소유권확인·토지분할·토지경계확정 등)가 있다.

(나) 구체적 사항의 예시

① 경계확정사건

㉠ 양쪽 당사자가 가리키는 경계의 상황, 특히 가리키는 지점의 특성, 지점과 지점을 연결하는 선이 어떠한 선인가 및 경계선으로 볼 만한 표식

㉡ 분쟁부분의 상황

㉢ 다툼이 없는 원고 소유 토지의 상황

㉣ 다툼이 없는 피고 소유 토지의 상황

② 교통사고로 인한 손해배상사건

㉠ 사고 현장 부근의 도로, 공작물의 상황

㉡ 사고 현장의 상황

도로의 폭, 경사, 노면, 도로표식, 도로시설(신호등·횡단보도·가드레일) 등의 상황

㉔ 당사자가 가리키는 사고지점의 위치·상황

㉕ 관계지점에서 본 상황

원고 측이 가리키는 지점을 기준으로 한 결과, 피고 측이 가리키는 지점을 기준으로 한 결과

③ 일조권침해를 원인으로 한 손해배상사건

㉔ 건물 상호 간의 위치관계, 방위·거리·높이 등

㉕ 검증할 때의 가옥 내부의 밝기

㉖ 습도상황

㉗ 원고 건물과 주위의 상황

㉘ 그림자가 비치는 상황

(6) 도면과 사진

조서에는 도면·사진 기타 법원이 적당하다고 인정한 것을 인용하고 소송 기록에 첨부하여 조서의 일부로 할 수 있는데(민소 156조, 160조), 도면이나 사진의 첨부가 가장 많이 활용되는 분야가 검증조서이다. 도면이나 촬영한 사진을 조서에 첨부하는 것이 문장으로 표현하는 것보다 검증결과를 이해하는 데 훨씬 효과적인 경우가 많은 까닭이다.

도면을 작성하는 경우에는 보통 현장에서 스케치해 두었다가 사무실에서 정리하게 되는데, 스케치 자체를 정확하고 치밀하게 하여야 한다. 도면은 보통 평면도만으로 족한 경우가 대부분이지만 필요한 경우에는 입체도·단면도·확대도(도면 중의 특정부분을 확대한 도면) 등을 작성할 수도 있고, 수개의 도면이 작성된 경우에는 제1도면, 제2도면 등으로 구분 표시해 두어야 한다.

거리의 표시는 점선, 경계의 표시는 실선, 원고 소유 대지는 적색, 피고 소유 대지는 청색으로 표시하는 등 검증조서의 도면작성에는 작성자의 노력이 그대로 반영되므로 꾸준히 연구할 필요가 있다.

사진은 목적물 그 자체를 정확히 표상하는 데는 유용하지만, 한 면밖에 찍히지 아니하므로 전체를 나타내기 위하여 다른 각도에서 여러 장을 찍어야 할 필요가 있으므로 주의하여야 한다. 이러한 경우에는 사진에 번호를 붙이고 어느 방향에서 찍은 것이라는 것을 부기해 두는 것이 좋다. 실물의 크기·넓이 등을 정확히 알 필요가 있을 경우에는 누가 보아도 그 크기를 알 수 있는 것(명함·사람 등)과 함께 찍는 것도 한 방법이고, 검증 당시에 촬영한 것임을 나타내기 위하여 검증 시에 참여한 소송관계인이 화면에 나오도록 촬영하는 것도 한 방법이다.

라. 검증조서의 작성 실례

(1) 건물 점유상황의 검증과 측량감정을 행한 경우

1. 검증의 목적물

○○시 ○○동 ○○로 100 지상의 건물 일체

2. 검증 목적

위 건물의 피고별 점유 여부 및 그 위치를 확인하고 감정인에게 각 피고의 점유부분의 위치·면적에 관한 감정을 명함에 있다.

3. 검증장소의 위치

이곳 현장은 ○○, ○○간 도로(편도 3차선)의 ○○기점 약 500m 지점에 위치한 별지 제1도면 표시 ○○슈퍼 옆으로 난 골목을 따라 약 400m 걸어 들어간 같은 도면 표시 사선 부분에 위치하고 있다.

4. 검증결과

가. 현장의 상황

위 대지 중 도로로부터 가장 안쪽인 별지 제2도면 (1) 부분에 안채인 ‘ㄱ’자형의 벽돌조 슬래브지붕 단층주택이 있고(사진 ① 참조), 도로에 면한 서남쪽 부분인 위 도면 (2)(3)(4)(5) 부분에 ‘ㄴ’자형의 목조 기와지붕 단층 점포 겸 창고, 동남쪽 구석인 위 도면 (6) 부분에 목조 기와지붕 단층 화장실이 각 위치하고 있으며, 위 (5) 부분과 (6) 부분 사이에 안채로 통하는 대문이 있는데, 이 대문 위에도 기와지붕이 양쪽 건물에 연결 설치되어 있어 전체적으로는 위 (2) 내지 (6) 부분이 ‘ㄴ’자형의 행랑채 형태로 되어 있으며(사진 ②, ③ 참조), 이 행랑채와 위 안채 사이의 공간은 안채의 마당으로 사용되고 있다.

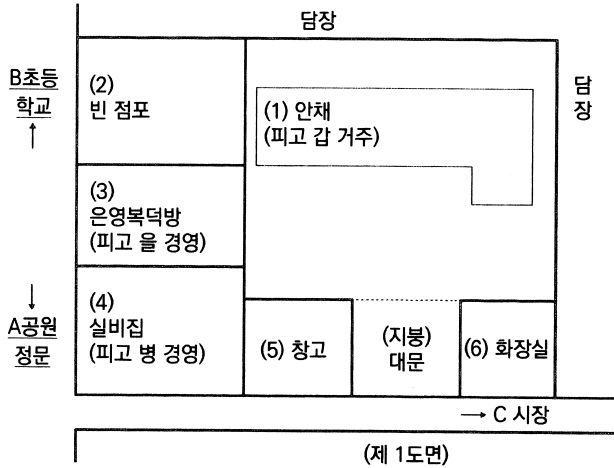
나. 위 각 건물 중,

- (1) 위 (1) 부분은 피고 갑(甲)이 주택으로 거주 사용하고 있고, 위 (6) 부분은 그에 딸린 화장실로 사용하고 있으며,
- (2) 위 (3) 부분은 피고 을(乙)이 은영복덕방이라는 상호의 소개영업소로 사용하고 있고(사진 ④ 참조),
- (3) 위 (4) 부분은 피고 병(丙)이 실비집이라는 상호의 간이주점영업소 겸 살림집(안집)으로 사용하고 있음(사진 ⑤ 참조)을 각 확인할 수 있다.
- (4) 한편 나머지 부분 중 위 (2) 부분은 빈 점포로서 안에 아무 것도 없이 폐점 상태이고, 위 (5) 부분은 창고로서 안에 잡다한 살림·폐품 등이 가득 차 있는바, 현장에 있는 피고 갑(甲)은 이 두 부분 모두를 자신이 관리 점유하고 있다고 설명하였다.

다. 피고별 각 점유부분의 정확한 위치와 면적은 감정인의 감정에 의하지 않고는 확인할 수 없다.

이 검증은 15 : 00 시작하여 16 : 00 종료하였다.

도면 1매, 사진 5매 각 첨부



(2) 인접 토지의 경계선 부근상황의 검증과 측량감정을 행한 경우

1. 검증의 목적물

원고 소유인 ○○시 ○○동 187의 6 대지와 피고 소유인 같은 번지의 5 대지 및 각 지상의 건물 등

2. 검증 목적

위 두 토지의 경계선 부근의 현황을 확인하고 감정인에게 두 토지의 정확한 경계선과 쌍방의 침범 점유 여부 및 그 위치·면적에 대한 감정을 명함에 있다.

3. 검증장소의 위치

이곳 현장은 ○○, ○○간 도로(편도 3차선)의 ○○기점 약 300m 지점에 위치한 별지 제1도면 표시 ○○미장원 옆으로 난 골목을 따라 약 100m 걸어 들어간 같은 도면 표시 사선 부분에 위치하고 있다.

4. 현장에서의 당사자 주장

가. 원고 대리인

지적도상의 경계선은 대략 위 도면 ㄱ, ㄴ, ㄷ 점을 연결한 선이며, 따라서 피고가 원고 소유 대지 중 ㄴ, 3, ㄷ, ㄴ 점을 연결한 선내부분(사선표시 부분)을 침범 점유하고 있다고 진술

나. 피고

위 진술내용을 부인하고, 약 25년 전에 전소유자로부터 매수하였는데, 당시 이미 설치되어 있던 위 시멘트블록담장이 지적도상의 경계선인 것으로 확신하고 점유하여 왔다고 진술

5. 검증결과

가. 현장의 상황

① 피고가 점유 사용하는 대지는 별지 제2도면 1, 2, 3, 4, 1의 각 점을 연결한 선내부분이고, 원고가 점유사용하는 대지는 같은 도면 2, 5, 6, 3, 2의 각 점을 연결한 선내부분인데, 위 두 대지는 위 2, 3 점의 연결선상에 축조된 높이 약 1.8m의 시멘트블록담장을 경계로 하여 인접하고 있다(사진 ① 참조).

② 피고 점유 대지 중 위 도면 (A) 부분에는 시멘트블록조 슬레이트지붕 단층 주택(사진 ② 참조)이, 위 도면 ①, ②, ③, ④점을 연결한 선내 부분에는 시멘트블록조 슬래브지붕의 광 및 화장실이 각 위치하고 있는데, 그 슬래브지붕 위는 장독대로 사용되고 있다(사진 ③ 참조). 또 위 도면의 점선과 위 시멘트블록담장 사이의 공간에는 정원석으로 가장자리를 쌓은 화단이 위치하고 있다.

③ 원고 점유 대지상에는 위 도면 (B) 부분에 벽돌조 기와지붕 단층 주택이 위치하고 있다(사진 ④ 참조).

나. 위 두 토지의 점유 사용현황은 앞서 본 것과 같은바, 위 두 토지 사이의 정확한 경계선과 피고가 원고 소유 토지를 침범 점유하고 있는지 여부 및 그 위치·면적은 감정인의 감정에 의하지 않고는 확인할 수 없다.

이 검증은 15:00 시작하여 16:00 종료하였다.

도면 1매, 사진 5매 각 첨부

(3) 다툼의 대상이 된 토지 주변의 현황에 대한 검증만을 행한 경우

1. 검증의 목적물

충주시 ○○면 ○○리 산18의 6 토지 및 그 지상 시설 등

2. 검증 목적

위 토지 및 그 주변 토지의 현황과 지상 시설물을 확인함에 있다.

3. 검증장소의 위치

…… (생략) ……

4. 검증결과

가. 위 도로(중부고속도로 진입로에서 ○○리로 가는 비포장도로)에서 본건 계쟁 토지 입구까지는 거리 약 100m, 폭 약 3m의 시멘트 포장도로로 연결되어 있는데, 이 시멘트 포장도로의 우측에는 각종 정원수 묘목이 밀식된 묘포가 있고 좌측에는 비닐하우스가 10여 채 들어서 있다(사진 ① 참조). 지적도와 대조해 볼 때 위 묘포는 같은 리 산18의 3 입야의 일부이고, 위 비닐하우스부지는 같은 리 587 밭의 일부인 것으로 보인다.

나. 본건 계쟁 토지의 입구에는 두 개의 시멘트기둥으로 된 정문이 있고 ‘영진농장’이라는 간판이 걸려 있으며(사진 ② 참조), 그 양쪽으로 철조망 울타리가 설치되어 위 토지 전체를 둘러싸고 있다.

다. 위 정문으로 들어가 보니 약 60평 면적의 공터가 있고 그 좌측에는 벽돌조 슬래브지붕 2층 주택이, 우측에는 시멘트블록조 슬레이트지붕 창고가 각각 위치하고 있는데(사진 ③ 참조), 위 공터로부터 별지 제3도면 점선 표시와 같이 동북쪽으로 맞은편 끝의 철조망까지 소로가 나 있고(사진 ④ 참조), 이 소로를 중심으로 위 토지 전체가 좌우로 양분된 형태로 되어 있다.

라. 위 소로의 좌측(서북쪽)부분 지상에는 배나무가, 우측(동남쪽)부분 지상에는 사과나무가 각각 수백 주씩 식재되어 있는데(사진 ⑤⑥ 참조), 현장에 있는 관리인 김○○의 설명에 의하면 위 배나무는 피고가 2002년 봄에 700주 심은 것이고 위 사과나무는 피고가 2001년 가을에 500주 심은 것이라고 한다.

마. 위 공터로부터 위 소로를 따라 약 200m 거리의 지점 우측 노변에 인접하여 분묘 1기가 설치되어 있는데 봉분만 있을 뿐 비석·상석 등 시설물은 전혀 없다(사진 ⑦ 참조).

바. 현장에 있는 원고는 위 분묘가 원고의 증조부인 망 ○○○의 분묘라고 설명하면서 원고의 망부 ○○○가 피고의 망 조부 ○○○에게 본건 계쟁토지를 매도할 때 위 분묘를 중심으로 주위의 250평 부분을 제외하고 나머지 부분만을 매도하였다고 주장하므로 재판장이 원고에게 그 250평 부분을 특정 지적하도록 명하였으나, 원고는 구체적 위치를 잘 모른다고 하면서 지적하지 아니하였다.

사. 위 분묘 주변을 살펴보았으나 원고 주장의 위 250평 부분을 구별할 수 있는 표지물이나 자연적 경계 등은 전혀 발견할 수 없었다.

아. 한편 현장에 있는 피고 및 관리인 김○○은 원고가 그간 한번도 성묘를 온 적이 없기 때문에 원고를 오늘 처음 대면하였다고 진술하였다.
이 검증은 15 : 00 시작하여 16 : 00 종료하였다.
도면 1매, 사진 5매 각 첨부

(4) 건물 개축상황의 검증과 시가감정을 행한 경우

1. 검증의 목적물

서울 ○○구 ○○동 101 서울빌딩 2층

2. 검증 목적

이 사건 건물 내부 및 그 벽의 통풍기 설치와 방수벽 설비에 관한 현상을 확인하고, 감정인에게 방수벽 설치로 인한 필요비 또는 유익비 등의 감정을 명함에 있다.

3. 검증장소의 위치

현장은 서울 종로 5가 네거리에서 혜화동에 이르는 중간지점(약 150m)으로, 북부세무서 맞은편 대로변에 위치한 별지 도면 A표시 부분인바, 위 대로에 접한 부분을 제외한 삼면 중 남쪽은 신일빌딩에, 북쪽은 영풍양복점에, 서쪽은 다른 사람의 주택에 각 접하고 있다.

4. 현장에서의 당사자의 주장

가. 원고 대리인

건물 신축 후 2회 개축하였으며, 피고들에게 임대하기 전에 통풍·방수설비 등 완전 설비를 하였고, 그 후 아무런 시설을 한 흔적이 없다.

나. 피고들 대리인

이 건 점포에 비하면 2층 1호실 7평은 통풍기 시설을 하지 않아 벽에 곰팡이가 끼어 있다. 다툼의 대상이 된 건물에 대한 시설 유무는 페인트 빗갈 등의 현상으로도 쉽게 알 수 있다.

5. 검증결과

가. 이 건 건물은 대로면에 접한 동쪽 벽에 가로 85cm, 세로 104cm의 유리창이, 서쪽 벽에 출입문이 있었고 낮에도 형광등이 켜 있으므로 실내조명이 가능했다.

나. 북쪽 벽 상단에는 「혜성사」 제품 'RC-80'형 통풍기가 부착되어 계속 작동 중이었다.

다. 남·북쪽 벽은 하얀 빛깔로, 서쪽 벽은 빛바랜 노랑 페인트로 도장되어 있었다.

라. 설비된 벽이 방수벽인지, 언제 설치했는지는 감정인의 감정에 의해서 밝혀지겠다.

이 검증은 15 : 00 시작하여 16 : 00 종료하였다.

도면 1매, 사진 5매 각 첨부

(5) 필적 또는 인영을 대조하는 검증을 한 경우

1. 검증의 목적물

갑 제4호증(각서)에 찍힌 피고의 인영과 을 제3호증의5(진술조서)에 찍힌 피고의 인영

2. 검증 목적

위 두 인영을 대조하여 그 동일 여부를 확인함에 있다.

3. 검증의 결과

위 두 서면의 원본에 의하여 위 두 인영을 면밀히 대조해 본 결과, 인영의 크기·자체 등이 완전히 동일함이 육안으로도 분명하였다(또는 …… 동일함을 육안으로 확인할 수 있다).

이 검증은 15 : 00에 시작하여 15 : 10에 종료하였다.

위 두 문서 중 인영이 찍힌 부분의 사본 각 1매씩 첨부

제3절 사실조회(조사·송부의 촉탁)

1. 의 의

사실조회란 공공기관·학교, 그 밖의 단체·개인 또는 외국의 공공기관에게 그 업무에 속하는 특정사항에 관한 조사 또는 보관 중인 문서의 등본·사본의 송부를 촉탁함으로써 증거를 수집하는 절차를 말한다. 민사소송법에는 증거에 관한 총칙 중에 ‘조사의 촉탁’으로 규정되어 있으나(민소 294조), 그 실질은 증인신문 등과 마찬가지로의 독립한 증거방법으로 이해되고 있으며 실무에서는 이를 사실조회라고 부른다.

이러한 공공기관 등의 관장사항에 관하여는 증인신문·서증조사 등에 의하여 법원이 직접 증거자료를 탐지하는 것보다 그 공공기관 등에게 조사를 촉탁하여 그 결과를 회신하도록 하는 것이 훨씬 능률적이므로, 실무에서는 당사자의 신청 또는 직권에 의한 증거결정에 의하여 활발하게 이용되고 있다.

민사소송법은 단체뿐만 아니라 전문적이고 특수한 분야에 관한 지식이나 정보를 갖고 있는 개인에게도 사실조회를 할 수 있고, 사실조회의 한 방법으

로 대상자가 보관중인 문서의 등·사본을 송부할 것을 촉탁할 수 있다는 것을 명확히 규정하고 있다.

종래 법원에서 각종 재판 중에 통신내역을 전기통신사업자에게 사실조회 등으로 요청한 경우 이를 거부하는 사례가 있어서, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 통신비밀보호법 13조의2는 법원이 재판상 필요한 경우에는 민사소송법 294조 또는 형사소송법 272조의 규정에 의하여 전기통신사업자에게 통신사실확인자료제공을 요청할 수 있도록 규정하였다.

사실조회는 촉탁의 상대방이 용이하게 조사할 수 있는 사실에 대하여 조회하고, 조사할 내용이 촉탁의 상대방의 특별한 지식과 경험을 필요로 하는 것이거나 촉탁의 상대방의 전문적인 의견을 구하는 것일 때에는 감정촉탁의 방법으로 함이 상당하다(사실조사비용예규 2조).

사실조회회보가 공문서인 경우 별도의 신빙성 있는 반대자료가 없는 한 법원은 그 기재와 어긋나는 사실 인정을 할 수 없다(대법원 1990. 11. 23. 선고 90다카21022 판결).

2. 사실조회공문의 발송

사실조회를 하기로 하는 증거결정을 한 때에는 재판장 명의로 사실조회서[전산양식 A1840]를 작성하여 발송한다. 민사소송규칙은 사건기록이 전자기록으로 관리되는 전자기록사건에서 사실조회를 하는 방법 등에 관하여 특칙을 마련하고 있다. 법원은 전자소송시스템에 사실조회 기관으로 등록된 기관에 대하여는 사실조회를 전자적인 방법으로 촉탁할 수 있다(민전규 37조 3항, 민전예규 85조 1항). 법원이 사실조회 기관으로 등록되지 않은 기관에 대하여 사실조회를 촉탁할 때에는 촉탁을 받은 기관이 사실조회 회신을 전자적인 방법으로 할 수 있도록 전자소송인증번호를 부여한다(민전예규 85조 2항).

법원은 사실조회를 하는 때에는 필요한 범위 내에서 개인정보 보호법 23조 내지 24조의2의 민감정보, 고유식별정보, 주민등록번호 및 그 밖의 개인

정보가 포함된 자료의 송부를 요구할 수 있다(민소규 76조의2 2항). 신청인 등 당사자에게 사실조회 회답서를 교부하여야 하는 경우에 대비하여, 법원은 조 회상대방에게 사실조회 회답서의 부분을 제출하게 할 수 있다(민소규 76조).

[전산양식 A1840] 사실조회서

○ ○ 법 원 사실조회		귀하
사	건	20○○가○○○
원	고	
피	고	
위 사건의 심리를 위하여 민사소송법 제294조에 의거하여 다음 사항을 조회하오니 회보하여 주시기 바랍니다. 위 사건의 다음 재판기일이 20○○. ○. ○. 이므로 그 이전까지 회보서가 도착되도록 배려하여 주시기 바랍니다. 조회사항 : 별지와 같음 ※ 회보서에는 당원의 사건번호(20○○가○○○)를 반드시 기재하여 주시기 바랍니다. ※ 사실조회회신은 “대한민국 법원 전자소송포털 → 서류제출 → 회신서 등 제출 → 사실조회회신서 선택 → 회신서 파일제출”의 방법으로 할 수 있습니다. 20○○. ○. ○. 판 사 ㉮		
※ 문의사항 연락처 : ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○ 전화 : ○○○ — ○○○○ 팩스 : ○○○ — ○○○○ 주소 : e-mail :		

사실조회 신청 등에 대하여 증거신청에 대한 의견진술이 필요하다고 인정되는 경우에는 상대방에게 신청 및 채택 사실을 고지하여 의견진술이나 참여의 기회를 부여하는 것이 상당하다.

[전산양식 A1841] 사실조회에 따른 독촉

○ ○ 법 원
사실조회에 따른 독촉

귀하

사 건 20○○가단(합, 소)
원 고
피 고

[담당재판부: 제 단독(부)]

제28장

감정·검증·사실조회

평소 우리 법원의 업무에 적극 협조하여 주시고 있는 데 대하여 감사드립니다.
위 사건에 관하여 사실조회를 의뢰하였는바, 그 회신이 도착하지 아니한 관계로
재판이 오래 지연되고 있습니다.

여러 업무에 바쁘신 줄은 잘 알고 있으나, 사실조회에 대한 회신서를 가능한 한
조속히 송부하여 주실 것을 부탁드립니다(다음 재판기일: 20○○. ○. ○.).
아울러 빠른 시일 내에 회신서의 송부가 불가능할 경우에는 그 이유 및 송부 가
능한 시기를 알려 주시기 바랍니다.

※ 우리 법원이 발송한 사실조회서가 귀하에게 도착된 일자는 20○○. ○. ○. 입니다.

20○○. ○. ○.
재판장 판사 ㉠

※ 이 법원에 제출하는 서면에는 사건번호(20○○가)를 반드시 기재하여 주시
기 바랍니다.

※ 문의사항 연락처 : ○○법원 제○민사부 법원사무관 ○○○
전화 : ○○○ — ○○○○
팩스 : ○○○ — ○○○○ e-mail : @scourt.go.kr
주소 :

조회 상대방이 외국의 공공기관일 경우에는 외국에서 시행하는 증거조사
(민소 296조)에 해당하므로 국제민사사법공조법상의 촉탁경로에 따라 사실조
회서를 발송하여야 하지만, 조회 대상기관이 외국 주재의 우리나라 대사·영

사 등이고 조회사항도 해당 대사관 또는 영사관의 담당사무 자체에 관한 것 일 때에는 위 법상의 촉탁경로에 의할 것 없이 재판장이 직접 해당 대사 또는 영사에게 사실조회서를 통상의 외국우편으로 발송하면 된다. 자세한 내용은 제40장(국제민사사법공조) 참조.

회보가 늦어지는 경우에는 소송촉진을 위하여 사실조회에 따른 독촉[전산양식 A1841]을 발송하는 것이 바람직하다. 또한 회보가 왔으나 불충분하거나 불명확하여 다시 보충적인 조회를 할 필요성이 있는 경우에는, 재판장은 이를 촉구하는 공문을 발송하여야 한다.

3. 회보가 도착한 경우의 처리

전자기록사건에서 법원으로부터 조사 또는 문서의 송부를 촉탁받은 자가 그 촉탁사항이나 송부대상인 문서를 전자데이터 또는 전자문서로 가지고 있는 경우에는 전자소송시스템을 이용하여 이를 전송하여야 하고(민전규 37조 1항), 법원은 촉탁사항이나 송부대상인 문서가 전자데이터 또는 전자문서가 아닌 경우 이를 전자문서로 변환하여 전송하여 줄 것을 요청할 수 있다(2항). 회보가 도착한 때에는 즉시 양쪽 당사자에게 전화·팩시밀리 등 간이한 방법으로 그 사실을 즉시 통지하고[사건관리예규 12. 나. (5)], 변론(준비)기일에서 당사자에게 의견진술의 기회를 주는 절차를 거쳐야 하는데(대법원 1982. 8. 24. 선고 81누270 판결), 유리한 당사자가 이를 원용하는 수가 많다. 이에 관계되는 사항은 기본조서에 기재하며, 증인등목록의 '증거조사'란에는 발송일자 와 도착일자를 기재한다(민사증거목록예규 19조 3항).

회보에 관하여는 이를 따로 서증으로 제출시킬 필요는 없다. 회보처에서 참고서류 사본 등을 함께 보낸 경우에도 이를 포함한 전체를 사실조회결과로 처리하면 되며 그 참고서류를 따로 서증으로 제출할 필요는 없는데, 이 점에 있어서 문서송부촉탁의 경우와 다르다. 다만 해당 기관 이외의 자가 작성한 문서로서 단순한 참고서류가 아닌 정식의 문서가 포함되어 있는 경우에는 이를 증

거로 하려면 별도의 서증으로 제출받아야 한다. 이 경우에는 그 사본을 다시 제출할 필요는 없고 첨부되어 온 서류에 직접 서증번호를 부기하면 된다.

4. 사실조회회보에 대한 비용 지급

조사촉탁의 상대방의 청구에 의하여 민사소송비용법 9조에 의한 비용을 지급하는 절차에 대하여는 ‘사실조사 촉탁 등의 비용 지급에 관한 예규’가 규정하고 있다.

법원은 신청인 또는 조사로 인하여 이익을 받을 당사자에게 조사에 소요되는 비용의 예납을 명할 수 있고, 그 이익을 받을 당사자가 불명한 때에는 원고에게 그 예납을 명할 수 있다(사실조사비용예규 3조). 법원은 필요한 경우에는 촉탁의 상대방에게 조사에 소요되는 예상비용액 산정서를 제출하게 할 수 있고, 도착된 예상비용액 산정서 또는 조사촉탁할 내용을 종합하여 예납할 금액을 정한다(사실조사비용예규 4조). 그리고 촉탁의 상대방은 법원에 조사보고서를 제출할 때 비용청구서를 함께 제출하여야 한다(사실조사비용예규 5조). 법원은 조사보고서와 비용청구서의 내용을 검토하여 상당하다고 인정하는 금액을 비용으로 지급한다(사실조사비용예규 6조).

5. 금융거래정보·과세정보 등 제출명령

금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 4조 1항 1호, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 32조 6항 5호, 국세기본법 81조의13 1항 3호, 지방세기본법 86조 1항 3호는 금융거래정보, 신용정보 또는 과세정보의 비밀 유지에 대한 예외 중 하나로 법원의 제출명령을 들고 있는데, 여기서 정한 법원의 제출명령의 범위, 형식 및 금융거래정보 통보비용의 지급에 관하여는 ‘금융거래정보·과세정보 제출명령에 관한 예규’가 제정되어 있다.

위 예규에서 법원의 제출명령은 법원이 금융기관, 신용정보를 처리하는 공공기관 또는 단체, 세무공무원에 대하여 금융거래정보나 신용정보, 과세정

보의 제출을 요구하는 ① 민사소송법 294조, 형사소송법 272조, 가사소송법 8조에 의한 사실조회, ② 민사소송법 347조에 의한 문서제출명령, ③ 민사소송법 352조에 의한 문서송부촉탁, ④ 민사소송규칙 112조에 의한 법원 밖 서증조사 시 문서제출의 요구, ⑤ 민사집행법 237조, 291조에 의한 압류(또는 가압류) 명령 시 진술최고, ⑥ 기타 법원이 금융기관, 신용정보를 처리하는 공공기관 또는 단체, 세무공무원에 대하여 금융거래정보나 신용정보 또는 과세정보의 제출을 요구하는 일체의 처분 중 그 처리절차에 관하여 특별한 규정이 없는 처분을 말한다(금융거래정보·과세정보 제출명령에 관한 예규 2조). 따라서 재산조회규칙 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 규칙 등과 같이 재산조회에 관하여 별도의 규정을 둔 경우는 그 규정에 정한 바에 따른다.

위 소송법 규정만을 근거로 자료를 요청할 경우 대상기관에서 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 소정의 제출명령에 해당하지 않는다는 이유로 자료제출을 거부하는 사례가 생길 우려가 있으므로, 위 제출명령은 금융위원회가 양식을 정한 제출명령[전산양식 A1842]을 사용하고, 위 양식 중 '요구의 법적 근거'란에는 소송법 규정 외에 위 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등의 규정을 함께 명시하여야 한다. 그 밖에 세무공무원에 대한 과세정보 제출명령은 [전산양식 A1844], 신용정보를 처리하는 공공기관 또는 단체에 대하여는 [전산양식 A1846]을 사용한다.

한편 금융기관은 법원의 제출명령에 의하여 거래정보를 제공한 경우에는 거래정보 제공사실 등을 명의인에게 서면으로 통보하여야 하고(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 4조의2 1항), 그 비용은 거래정보 등의 제공을 요구하는 자가 부담하여야 하므로(4항), 법원은 제출명령의 신청인, 신청인이 없는 경우에는 제출명령으로 이익을 받을 당사자, 이익을 받을 당사자가 불명할 때에는 원고에게 통보비용의 예납을 명하여야 하고(금융거래정보·과세정보 제출명령에 관한 예규 4조 1항), 예납을 명할 금액은 '금융기관 수×명의인 수×2,000원'이다(2항).

[전산양식 A1842] 제출명령(금융거래정보)

○ ○ 법 원
제 출 명 령

○○은행 ○○○지점장 귀하

사 건 20○○가합○○○ 손해배상
원 고 ○○○
피 고 ○○○

아래와 같이 금융거래정보의 제출을 요구합니다.

아 래

요 구 내 용	명의인의 인적사항	성 명	○ ○ ○
		주민등록번호	(○○○○○○○-○○○○○○○○)
		계 좌 번 호 (또는 증서번호)	
	요구대상 거래기간	20○○.○○.○○.부터 20○○.○○.○○.까지	
	요 구 의 법적근거	금융실명거래및비밀보장에관한법률 제4조 제1항, 민사소송법 제294조	
	사용목적	위 사건의 심리를 위하여	
통보 유예	요구하는 거래정보 등의내용	명의인의 ○○예금계좌에 대한 입출금내역 일체	
	유예기간		
	유예사유		
특이사항			

20○○. ○○. ○○.
재판장 판사 ㉠

※ 계좌번호, 통보유예, 특이사항은 필요한 경우에만 기재한다.

제28장
감정·검증·사실조회